

19/11/2024**PLENÁRIO****AÇÃO PENAL 2.011 DISTRITO FEDERAL**

RELATOR	: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
REVISOR	: MIN. NUNES MARQUES
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: VICENTE CAVALINI FILHO
ADV.(A/S)	: LUIZ FERNANDO VILASBOAS
ADV.(A/S)	: RHANA SARAIH MOTA DA SILVA

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. ACAMPAMENTO ILEGAL EM FRENTE DE QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO. DEFESA INCONSTITUCIONAL DE GOLPE DE ESTADO, INTERVENÇÃO MILITAR E ATAQUES À INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CRIMES MULTITUDINÁRIOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288, CAPUT) E INCITAÇÃO DE ANIMOSIDADE DAS FORÇAS ARMADAS CONTRA OS PODERES CONSTITUCIONAIS (CP, ART. 286, PARÁGRAFO ÚNICO). MATERIALIDADE E CO-AUTORIA DE VICENTE CAVALINI FILHO COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.

1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro, conforme já decidido por esse Plenário no momento do recebimento da denúncia. Precedentes.

2. Absoluto respeito ao Devido Processo Legal e seus princípios corolários: Ampla defesa e contraditório. Cerceamento de defesa inexistente, na medida em que à defesa foi oportunizada a utilização das faculdades processuais que asseguram a sua efetiva participação no impulsionamento e desdobramentos do feito, a viabilizar, inclusive, a utilização de todos os meios legítimos de prova para refutar a tese sustentada pela acusação na denúncia.

AP 2011 / DF

3. Contexto de crimes multitudinários. Acampamento em frente de Quartel General do Exército, em Brasília, com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados. Propósito criminoso amplamente difundido e previamente conhecido. Manifestantes induzindo e instigando as Forças Armadas à tomada inconstitucional de poder, mediante uso da força e quebra da normalidade democrática.

4. CONFISSÃO DO RÉU E DE 443 CO-AUTORES ao realizarem Acordos de não persecução penal (ANPP) com a PGR da prática dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288, *caput*) e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (CP, art. 286, parágrafo único). PROVA TESTEMUNHAL E PRISÃO DO ACUSADO no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército.

5. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL para CONDENAR o réu VICENTE CAVALINI FILHO, em concurso material (CP, art. 69) à (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, *caput*, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por pena restritiva de direitos; (2) 20 (vinte) dias multa, cada um no valor de ½ (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal; (3) R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatória à título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Virtual do Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, em conformidade com a ata de julgamento, por maioria, acordam em julgar procedente a ação penal para condenar o réu VICENTE CAVALINI FILHO, em concurso

AP 2011 / DF

material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, *caput*, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos, consistente em: (1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; (1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução; (1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena; (1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena; (1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado; (1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente; (2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais); (3) R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. Havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 5º, do Código Penal. Após o trânsito em julgado: (a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados; (b) expeça-se guia de execução definitiva. Custas pelo condenado (art. 804 do Código de Processo Penal). Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros ANDRÉ MENDONÇA e NUNES MARQUES.

Brasília, 19 de novembro de 2024.

AP 2011 / DF

Ministro ALEXANDRE DE MORAES

Relator

Documento assinado digitalmente

19/11/2024**PLENÁRIO****AÇÃO PENAL 2.011 DISTRITO FEDERAL**

RELATOR	: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
REVISOR	: MIN. NUNES MARQUES
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: VICENTE CAVALINI FILHO
ADV.(A/S)	: LUIZ FERNANDO VILASBOAS
ADV.(A/S)	: RHANA SARAIH MOTA DA SILVA

RELATÓRIO

O Senhor Ministro Alexandre de Moraes (Relator): Trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputando ao acusado **VICENTE CAVALINI FILHO**, brasileiro, nascido em 17/01/1969, filho de Vicente Cavallini e Maria Edithe Chalegre Cavallini, CPF nº 715.374.069-49, residente na Rua General Carneiro, n. 811, Bairro Centro, Camargo/PR, CEP n. 87155-000, a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e 288, *caput* (associação criminosa), observadas as regras do art. 69, *caput* (concurso material), todos do Código Penal.

De acordo com a peça acusatória, os fatos criminosos imputados circunscrevem-se aos delitos acima referidos, na medida em que o acusado se associou a outros manifestantes (réus em ações penais diversas, em curso perante esta Corte), em acampamento instalado em frente ao Quartel-General do Exército, localizado em Brasília/DF, com o objetivo de praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito, passando a incitar, publicamente, animosidade das Forças Armadas contra os demais Poderes da República.

O Subprocurador-Geral da República, na cota de oferecimento da denúncia, consignou que, *“em razão da complexidade dos fatos e da investigação, que não há arquivamento explícito ou implícito em relação a*

AP 2011 / DF

nenhum outro potencial crime que possa ter sido cometido pelo denunciado, haja vista a possibilidade de elucidação de novas condutas delituosas a partir da chegada dos laudos periciais, imagens, geolocalização, oitivas de testemunhas e vítimas das agressões ou qualquer outra prova válida”, reservando-se no direito de aditar a peça acusatória ou de oferecer novas denúncias, caso sejam elucidados novos delitos por ele praticados.

VICENTE CAVALINI FILHO foi notificado, no Centro de Detenção Provisória II do Complexo Penitenciário do Distrito Federal para apresentar resposta à denúncia no prazo legal, oportunidade na qual, por meio da defesa constituída, requereu, em síntese, a incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para julgar o presente caso; a inépcia da denúncia em razão da ausência de descrição pormenorizada das condutas do acusado; a inexistência de incitação à prática de crime e a inexistência de associação criminosa (eDoc 19).

A denúncia foi recebida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE em acórdão publicado em 9/6/2024 (eDoc. 22), assim ementado:

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.

1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro.

2. O Acordo de não persecução penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova

AP 2011 / DF

realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes.

3. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio.

4. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos.

5. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.

6. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.

7. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de VICENTE CAVALINI FILHO, pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.

O Tribunal, por maioria, recebeu a denúncia oferecida em relação aos crimes previstos nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, nos termos do voto do Relator,

AP 2011 / DF

vencidos os Ministros NUNES MARQUES e ANDRÉ MENDONÇA, que, preliminarmente, reconheciam a incompetência do Supremo Tribunal Federal e, superada essa questão, rejeitavam a denúncia (Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 16.5.2023 a 22.5.2023).

Em 15/8/2023, a ação penal foi a mim distribuída e na mesma data, determinei a citação do réu (eDoc. 24).

O réu foi citado em 9/3/2024 (eDoc. 60) e, por meio de defensor constituído, apresentou defesa prévia em 1/3/2024, oportunidade em que arrolou 4 (quatro) testemunhas (eDoc. 51).

Nos termos da decisão replicada do Inquérito 4921, determinou-se o sobrestamento da ação penal, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, para possibilitar a realização de Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 26).

Diante da manifestação da Procuradoria-Geral da República, noticiando a recusa expressa do denunciado em firmar o Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 41), os autos retomaram seu regular seguimento.

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei audiência de instrução que foi realizada pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Rafael Henrique Janela Tamai Rocha, na data de 29/5/2024, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia, quais sejam, Carlos Eduardo Melo de Souza e José Roberto Soares da Silva e Ronaldo Pires da Rocha, com exceção da testemunha Hermison Bernardes Rangel, dispensada pela Procuradoria-Geral da República (eDocs. 77-82).

Designada audiência em continuação da instrução para o mesmo dia 29/5/2023, foi realizado o interrogatório do réu (eDoc. 84). Os termos de audiência, bem como a gravação dos respectivos atos, foram disponibilizados nos autos pela Secretaria Judiciária (eDocs. 82 e 85).

Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República. A defesa requereu a juntada “de documentação complementar” (eDocs. 89-91).

Em despacho de 17/6/2024, determinei a abertura de vista para a

AP 2011 / DF

apresentação, sucessivamente, das alegações finais, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 93). Na mesma oportunidade, determinei à Secretaria Judiciária que oficiasse aos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Tribunais Regionais Eleitorais da residência da acusada, bem como ao TJDF e TRF1, para que enviassem as certidões de antecedentes criminais do acusado, observando que, na hipótese de ser positiva, deveria vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado (eDoc. 83).

Em resposta foram encaminhadas as seguintes certidões: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDoc. 100), Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDoc. 101), Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc. 103), Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eDoc. 104), todas negativas.

Em 26/6/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou os seguintes argumentos em alegações finais (eDoc. 105):

1) os atos praticados pelo réu resultaram em dano concreto à segurança nacional e ao regime representativo e democrático;

2) a participação do acusado, de forma estável e permanente, no acampamento localizado em frente ao Quartel-General do Exército, incitando publicamente a prática de atos que buscavam a abolição do Estado Democrático de Direito e a destituição do governo legitimamente eleito, permitem o enquadramento de sua conduta nos termos do art. 268, parágrafo único, do Código Penal;

3) de forma a reiterar a sua adesão à finalidade antidemocrática, mesmo após os atos de 8.1.2023, o acusado permaneceu acampado em frente ao Quartel-general em Brasília, o que resultou em sua prisão em flagrante em 9.1.2023;

Requeru, ao fim, a *PROCEDÊNCIA* da ação penal pública *para condenar o réu Vicente Cavalini Filho pelas condutas penais de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal) e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art.*

AP 2011 / DF

286, parágrafo único, do Código Penal), em concurso material (art. 69, caput, do Código Penal).

Por fim, em 12/7/2024, a Defesa de **VICENTE CAVALINI FILHO** apresentou alegações finais, formulando, ao final, os seguintes requerimentos (eDoc. 111):

“i) O reconhecimento da nulidade em razão da incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar o feito com a consequente anulação dos atos praticados por esta corte no âmbito da Ação Penal 1.879-DF e o declínio de competência para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 109, inciso IV da Constituição Federal c.c artigo 564, inciso I do Código de Processo Penal;

ii) O reconhecimento da nulidade em razão da violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal c.c Sumula Vinculante n. 14, com o consequente arquivamento da ação penal;

iii) O reconhecimento da nulidade em razão da omissão de formalidade, nos termos do artigo 564, inciso IV do Código de Processo Penal, com o consequente arquivamento da ação penal;

iv) Subsidiariamente, a absolvição do réu por ausência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal quanto aos delitos de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (artigo 286, parágrafo único do Código Penal) e associação criminosa (artigo 288, caput do Código Penal);

v) Subsidiariamente, a absolvição do réu em razão de não ter restado provado que concorreu para a prática da infração, nos termos do artigo 386, inciso IV do Código de Processo Penal quanto aos delitos de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (artigo 286, parágrafo único do Código Penal) e associação criminosa (artigo 288, caput do Código Penal);

AP 2011 / DF

vi) Requer, o indeferimento do pedido de fixação de valor para reparação de danos, visto que o réu NÃO poderá ser responsabilizado por danos que decorrem de condutas que NÃO tem qualquer relação com a sua, isto porque, NÃO instigou ou fomentou a prática de atos de depredações contra prédios públicos que culminaram em prejuízos contra o patrimônio da união;

vii) Requer, ainda, a revogação das medidas cautelares impostas ao réu;

viii) Por fim, em caso de condenação, pugna pela pena no mínimo, diante das circunstâncias judiciais favoráveis e a aplicação do artigo 65, inciso II do Código Penal.”

É o relatório.

AÇÃO PENAL 2.011 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
REVISOR : MIN. NUNES MARQUES
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S) : VICENTE CAVALINI FILHO
ADV.(A/S) : LUIZ FERNANDO VILASBOAS
ADV.(A/S) : RHANA SARAIH MOTA DA SILVA

VOTO**O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR):**

Trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputando ao investigado **VICENTE CAVALINI FILHO**, brasileiro, nascido em 17/01/1969, filho de Vicente Cavallini e Maria Edithe Chalegre Cavallini, CPF nº 715.374.069-49, residente na Rua General Carneiro, n. 811, Bairro Centro, Doutor Camargo/PR, a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e 288, *caput* (associação criminosa), observadas as regras do art. 69, *caput* (concurso material), todos do Código Penal.

VICENTE CAVALINI FILHO foi notificado, no Centro de Detenção Provisória II do Complexo Penitenciário do Distrito Federal para apresentar resposta à denúncia no prazo legal, oportunidade na qual, por meio da defesa constituída, requereu, em síntese, a incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para julgar o presente caso; a inépcia da denúncia em razão da ausência de descrição pormenorizada das condutas do acusado; a inexistência de incitação à prática de crime e a inexistência de associação criminosa (eDoc 19).

A denúncia foi recebida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE em acórdão publicado em 9/6/2024 (eDoc. 22). Em 15/8/2023, a ação penal foi a mim distribuída e na mesma data, determinei a citação do réu (eDoc. 24).

O réu foi citado em 9/3/2024 (eDoc. 60) e, por meio de defensor constituído, apresentou defesa prévia em 1/3/2024, oportunidade em que arrolou 4 (quatro) testemunhas (eDoc. 51).

Nos termos da decisão replicada do Inquérito 4921, determinou-se o sobrestamento da ação penal, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, para possibilitar a realização de Acordo de Não Persecução Penal (eDoc.

AP 2011 / DF

26).

Diante da manifestação da Procuradoria-Geral da República, noticiando a recusa expressa do denunciado em firmar o Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 41), os autos retomaram seu regular seguimento.

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei audiência de instrução que foi realizada pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Rafael Henrique Janela Tamai Rocha, na data de 29/5/2024, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia, quais sejam, Carlos Eduardo Melo de Souza e José Roberto Soares da Silva e Ronaldo Pires da Rocha, com exceção da testemunha Hermison Bernardes Rangel, dispensada pela Procuradoria-Geral da República (eDocs. 77-82).

Designada audiência em continuação da instrução para o mesmo dia 29/5/2023, foi realizado o interrogatório do réu (eDoc. 84). Os termos de audiência, bem como a gravação dos respectivos atos, foram disponibilizados nos autos pela Secretaria Judiciária (eDocs. 82 e 85).

Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República. A defesa requereu a juntada de documentação complementar (eDocs. 89-91).

Em despacho de 17/6/2024, determinei a abertura de vista para a apresentação, sucessivamente, das alegações finais, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 93).

Em 26/6/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou os seguintes argumentos em alegações finais (eDoc. 105):

1) os atos praticados pelo réu resultaram em dano concreto à segurança nacional e ao regime representativo e democrático;

2) a participação do acusado, de forma estável e permanente, no acampamento localizado em frente ao Quartel-General do Exército, incitando publicamente a prática de atos que buscavam a abolição do Estado Democrático de Direito e a destituição do governo legitimamente eleito, permitem o enquadramento de sua conduta nos termos do art. 268, parágrafo único, do Código Penal;

AP 2011 / DF

3) de forma a reiterar a sua adesão à finalidade antidemocrática, mesmo após os atos de 8.1.2023, o acusado permaneceu acampado em frente ao Quartel-general em Brasília, o que resultou em sua prisão em flagrante em 9.1.2023;

Requeru, ao fim, a PROCEDÊNCIA da ação penal pública para condenar o réu *Vicente Cavalini Filho pelas condutas penais de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal) e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), em concurso material (art. 69, caput, do Código Penal)*.

Por fim, em 12/7/2024, a Defesa de **VICENTE CAVALINI FILHO** apresentou alegações finais, formulando, ao final, os seguintes requerimentos (eDoc. 111):

i) O reconhecimento da nulidade em razão da incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar o feito com a consequente anulação dos atos praticados por esta corte no âmbito da Ação Penal 1.879-DF e o declínio de competência para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 109, inciso IV da Constituição Federal c.c artigo 564, inciso I do Código de Processo Penal;

ii) O reconhecimento da nulidade em razão da violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal c.c Sumula Vinculante n. 14, com o consequente arquivamento da ação penal;

iii) O reconhecimento da nulidade em razão da omissão de formalidade, nos termos do artigo 564, inciso IV do Código de Processo Penal, com o consequente arquivamento da ação penal;

iv) Subsidiariamente, a absolvição do réu por ausência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal quanto aos delitos de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (artigo 286, parágrafo único do Código Penal) e associação criminosa (artigo 288, caput do Código Penal);

v) Subsidiariamente, a absolvição do réu em razão de não

AP 2011 / DF

ter restado provado que concorreu para a prática da infração, nos termos do artigo 386, inciso IV do Código de Processo Penal quanto aos delitos de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (artigo 286, parágrafo único do Código Penal) e associação criminosa (artigo 288, caput do Código Penal);

vi) Requer, o indeferimento do pedido de fixação de valor para reparação de danos, visto que o réu NÃO poderá ser responsabilizado por danos que decorrem de condutas que NÃO tem qualquer relação com a sua, isto porque, NÃO instigou ou fomentou a prática de atos de depredações contra prédios públicos que culminaram em prejuízos contra o patrimônio da união;

vii) Requer, ainda, a revogação das medidas cautelares impostas ao réu;

viii) Por fim, em caso de condenação, pugna pela pena no mínimo, diante das circunstâncias judiciais favoráveis e a aplicação do artigo 65, inciso II do Código Penal.

1. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

A competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o julgamento da presente ação penal já foi devidamente decidida pelo PLENÁRIO por ocasião do recebimento da denúncia (Sessão Virtual Extraordinária de 9/5/2023 a 15/5/2023), conforme se verifica no item 1 da EMENTA:

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.

1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de

AP 2011 / DF

evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro.

2. O Acordo de não persecução penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes.

3. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio.

4. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos.

5. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.

6. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.

7. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de VICENTE CAVALINI FILHO, pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e

AP 2011 / DF

288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.

No âmbito do Inq 4.922, instaurado objetivando a apuração das condutas omissivas e comissivas dos denominados EXECUTORES MATERIAIS, foram oferecidas 232 (duzentas e trinta e duas) denúncias, tendo todas sido recebidas por essa CORTE SUPREMA, com o reconhecimento de sua competência, além do recebimento de outras 1113 (mil, cento e treze) denúncias oferecidas e recebidas pelo PLENÁRIO pelos crimes previstos nos artigos 286, parágrafo único, 288, *caput*, nos termos do artigo 69, todos do Código Penal, a exemplo do presente feito.

Dessa maneira, a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para as ações penais referentes aos gravíssimos crimes praticados no dia 8 de janeiro foi analisada e reconhecida pelo Plenário da CORTE em 1.345 (mil, trezentos e quarenta e cinco) decisões.

Portanto, não prospera o argumento já rechaçado, de que esta CORTE SUPREMA seria incompetente para apurar, processar e julgar os fatos aqui narrados, pois a responsabilização legal de todos os autores e partícipes dos inúmeros crimes atentatórios ao Estado Democrático de Direito, que culminaram com as condutas golpistas do dia 08/01/2023, deve ser realizada com absoluto respeito aos princípios do Devido Processo Legal e do Juiz Natural, inclusive sem qualquer distinção entre servidores públicos civis ou militares.

As garantias fundamentais aos princípios do Devido Processo Legal e do Juiz Natural, diferentemente do que ocorria nos textos constitucionais anteriores, foram incorporadas ao texto da Constituição brasileira de 1988.

A garantia do Devido Processo Legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutório e plenitude de defesa, visando salvaguardar a liberdade individual e impedir o arbítrio do Estado.

A imparcialidade do Judiciário e a segurança do povo contra o arbítrio estatal encontram no Devido Processo Legal e no princípio do

AP 2011 / DF

Juiz Natural, proclamadas nos incisos LV, XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição Federal, suas garantias indispensáveis.

Como consagrado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

“O princípio da naturalidade do Juízo – que traduz significativa conquista do processo penal liberal, essencialmente fundado em bases democráticas – atua como fator de limitação dos poderes persecutórios do Estado e representa importante garantia de imparcialidade dos juízes e tribunais” (STF – 1ª T. – HC no 69.601/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 18 dez. 1992, p. 24.377).

O juiz natural é somente aquele integrado no Poder Judiciário, com todas as garantias institucionais e pessoais previstas na Constituição Federal, devendo a observância desse princípio ser interpretada em sua plenitude, de forma a não só proibir a criação de Tribunais ou juízos de exceção, como também exigir respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência, para que não seja afetada a independência e a imparcialidade do órgão julgador.

Nesse mesmo sentido, decidiu o TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÃO:

“O mandamento ‘ninguém será privado de seu juiz natural’, bem como ocorre com a garantia da independência dos órgãos judiciários, deve impedir intervenções de órgãos incompetentes na administração da Justiça e protege a confiança dos postulantes e da sociedade na imparcialidade e objetividade dos tribunais: a proibição dos tribunais de exceção, historicamente vinculada a isso, tem a função de atuar contra o desrespeito sutil a esse mandamento. Como esses dispositivos em sua essência concretizam o princípio do Estado de Direito no âmbito da constituição (organização) judiciária, elas já foram introduzidas na maioria das Constituições estaduais alemãs do século XIX, dando-lhes, assim, a dignidade de norma constitucional. O art. 105 da Constituição de Weimar deu prosseguimento a esse legado. À medida que os princípios do Estado de Direito e Separação de Poderes se foram aprimorando, também as prescrições

AP 2011 / DF

relativas ao juiz natural foram sendo aperfeiçoadas. A lei de organização judiciária, os códigos de processo e os planos de distribuição das causas (definidos nas Geschäftsordnungen – regimentos internos) dos tribunais determinavam sua competência territorial e material, (o sistema de) a distribuição das causas, bem como a composição dos departamentos individualizados, câmaras e senados. Se originalmente a determinação ‘ninguém será privado de seu juiz natural’ era dirigida sobretudo para fora, principalmente contra qualquer tipo de ‘justiça de exceção’ (Kabinettsjustiz), hoje seu alcance de proteção estendeu-se também à garantia de que ninguém poderá ser privado do juiz legalmente previsto para sua causa por medidas tomadas dentro da organização judiciária” (Decisão – Urteil – do Primeiro Senado de 20 de março de 1956 – 1 BvR 479/55 – Cinquenta anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Coletânea Original: Jürgem Schawabe. Organização e introdução. Leonardo Martins. Konrad Adenauer – Stiftung – Programa Estado de Derecho para Sudamérica, p. 900/901).

Em total e absoluta observância aos princípios do Devido Processo Legal e do Juiz Natural, o PLENÁRIO DA CORTE confirmou a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a presidência dos inquéritos que investigam os crimes previstos nos artigos 2º, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei 13.260/16, e no artigo 147 (ameaça), no artigo 147-A, § 1º, III, (perseguição), no artigo 163 (dano), no artigo 286 (incitação ao crime), no artigo 250, §1º, inciso I, alínea “b” (incêndio majorado), no artigo 288, *caput*, e seu parágrafo único (associação criminosa e associação criminosa armada), no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no artigo 359-M (golpe de Estado), todos do Código Penal (Inq. 4.879 Ref e Inq. 4.879 Ref-segundo, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe 10/04/2023).

Esta denúncia decorre de investigações conduzidas nesta SUPREMA CORTE, por meio dos Inqs. 4.917/DF, 4.918/DF, 4.919/DF, 4.920/DF, 4.921/DF, 4.922/DF, 4.923/DF e Pets dela derivadas, em razão dos atos que resultaram na invasão e depredação dos prédios do CONGRESSO NACIONAL, PALÁCIO DO PLANALTO e SUPREMO

AP 2011 / DF

TRIBUNAL FEDERAL ocorridos em 8/1/2023, caracterizando em tese os crimes de associação criminosa, incitação ao crime, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, e dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima.

A extensão e consequências das condutas de associação criminosa (art. 288, *caput*, do Código Penal) e das demais condutas imputadas ao denunciado são objetos de diversos procedimentos em trâmite neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL direcionados a descobrir a autoria dos financiadores e dos incitadores, inclusive autoridades públicas, entre eles aqueles detentores de prerrogativa de foro.

O Inq. 4.921 foi instaurado objetivando a apuração das condutas dos denominados PARTÍCIPIES POR INSTIGAÇÃO, pela prática dos crimes de incitação ao crime (artigo 286, parágrafo único, do Código Penal) e associação criminosa (artigo 288 do Código Penal), no contexto dos atos praticados em 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, especificamente nas sedes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do CONGRESSO NACIONAL e do PALÁCIO DO PLANALTO, bem como junto ao acampamento montado em frente ao QUARTEL GENERAL do Exército, em Brasília.

Nota-se, pois, que as investigações, analisadas as condutas em conjunto, têm por objeto, DENTRE OUTRAS, a prática do delito de associação criminosa, cujo objetivo principal é a prática de crimes, tais como abolição do Estado democrático de Direito (art. 359-L), e também golpe de Estado (art. 359-M), com deposição do governo eleito de forma legítima nas Eleições Gerais de 2022.

A pedido da Procuradoria-Geral da República, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL determinou a instauração de quatro Inquéritos: Inq. 4920, relativo aos FINANCIADORES dos atos antidemocráticos, que prestaram contribuição material/financeira para a malfadada tentativa de golpe; Inq. 4921, relativo aos PARTÍCIPIES POR INSTIGAÇÃO, que de alguma forma incentivaram a prática dos lamentáveis atos; Inq. 4922, relativo aos AUTORES INTELECTUAIS E EXECUTORES, que ingressaram em área proibida e praticaram os atos de vandalismo e destruição do patrimônio público; e Inq. 4923, relativo às AUTORIDADES DO ESTADO RESPONSÁVEIS POR OMISSÃO IMPRÓPRIA.

Todas as investigações referem-se aos mesmos atos criminosos

AP 2011 / DF

resultantes da invasão e depredação dos prédios do CONGRESSO NACIONAL, PALÁCIO DO PLANALTO e SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ocorridos em 08/01/2023, sendo EVIDENTE A EXISTÊNCIA DE CONEXÃO entre as condutas atribuídas a **VICENTE CAVALINI FILHO** na presente denúncia – por incursão nas penas previstas no artigo 286, § único, e no artigo 288, ambos do Código Penal – e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos referidos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro nessa SUPREMA CORTE.

Ressalte-se, inclusive, que alguns DETENTORES DE PRERROGATIVAS DE FORO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já foram identificados e estão sendo investigados, notadamente os Deputados Federais CARLOS JORDY, CABO GILBERTO SILVA, FILIPE BARROS e GUSTAVO GAYER.

Há, portanto, como bem sustentado pela Procuradoria-Geral da República, a ocorrência dos denominados delitos multitudinários, ou seja, aqueles praticados por um grande número de pessoas, em que o vínculo intersubjetivo é amplificado significativamente, pois *“um agente exerce influência sobre o outro, a ponto de **motivar ações por imitação ou sugestão**, o que é suficiente para a existência do vínculo subjetivo, ainda que eles não se conheçam”*.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público aponta que *“Não há dúvida, portanto, de que, nos atos do dia 8 de janeiro de 2023, todos agiam em concurso de pessoas, unidos pelo vínculo subjetivo para a realização da obra comum, devendo ser rigorosamente responsabilizados por seus atos”*.

Vislumbra-se, neste caso, que a prova das infrações supostamente cometidas por **VICENTE CAVALINI FILHO**, ou ainda, suas circunstâncias elementares, podem influir diretamente nas investigações envolvendo investigados com prerrogativa de foro.

Observe-se, ainda, que foi a própria Procuradoria-Geral da República, órgão máximo do Ministério Público da União e com atribuição para atuar perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que ofereceu a denúncia em virtude da competência desta CORTE para processar e julgar o presente caso, em face da CONEXÃO apresentada e pleiteia a manutenção do caso na CORTE, pois afirma que as investigações podem levar a novas imputações ao denunciado, o que por

AP 2011 / DF

si, também, afasta a alegação de violação do Promotor natural, como pretende a Defesa.

A comprovar que, de fato, as infrações praticadas e investigadas nos inquéritos mencionados possuem estreita relação.

Dessa maneira, nos termos do art. 76, do Código de Processo Penal, a competência deve ser determinada pela conexão:

I- se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;

II- se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;

III- quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

Não bastasse a existência de coautoria em delitos multitudinários, há, ainda, conexão probatória com outros dois inquéritos que tramitam no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que investigam condutas atentatórias à própria CORTE, o Inq 4.781, das “Fake News” e a prática de diversas infrações criminais por milícias digitais atentatórias ao Estado Democrático de Direito, investigada no Inq 4.874, cujos diversos investigados possuem prerrogativa de foro: Senador FLÁVIO BOLSONARO e os Deputados Federais OTONI DE PAULA, CABO JÚNIO DO AMARAL, CARLA ZAMBELLI, BIA KICIS, EDUARDO BOLSONARO, FILIPE BARROS, LUIZ PHILLIPE ORLEANS E BRAGANÇA, GUIGA PEIXOTO e ELIÉSER GIRÃO.

Dessa forma, não há dúvidas sobre a competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar e julgar a presente ação penal, pois É EVIDENTE A EXISTÊNCIA DE CONEXÃO entre as condutas atribuídas a **VICENTE CAVALINI FILHO** e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos referidos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro nessa SUPREMA CORTE, conforme já decidido em situações idênticas nos julgamentos de mérito das AP’s 1060, 1183 e 1502 (de minha relatoria, Sessões

AP 2011 / DF

Plenárias de 13/9/2023 e 14/9/2023).

Nesse exato sentido, analisando a presente hipótese, o PLENÁRIO dessa SUPREMA CORTE decidiu pela sua competência no momento do recebimento da denúncia:

Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. (INQ 4.921 RD-septingentésimo quinquagésimo nono, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 16/5/2023 a 22/5/2023)

Desta forma, não há dúvidas sobre a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o processo e julgamento da presente ação penal.

2. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E OMISSÃO DE FORMALIDADE

À defesa foi assegurada plena atuação em favor do réu durante todo o trâmite desta ação penal, com meios e recursos a ela inerentes e observância das garantias intrínsecas à própria concepção do devido processo legal.

A denúncia foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República e **VICENTE CAVALINI FILHO** foi notificado, no Centro de Detenção Provisória II do Complexo Penitenciário do Distrito Federal, apresentando sua resposta preliminar (eDoc 19).

A denúncia foi recebida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE em acórdão publicado em 9/6/2024 (eDoc. 22).

O réu foi citado em 9/3/2024 (eDoc. 60) e, por meio de defensor constituído, apresentou defesa prévia em 1/3/2024, oportunidade em que arrolou 4 (quatro) testemunhas (eDoc. 51).

Determinou-se o sobrestamento da ação penal, pelo prazo de 120

AP 2011 / DF

(cento e vinte) dias, para possibilitar a realização de Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 26).

Diante da manifestação da Procuradoria-Geral da República, noticiando a recusa expressa do denunciado em firmar o Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 41), os autos retomaram seu regular seguimento, com a realização da audiência.

A instrução ocorreu na audiência no dia 29/5/2023, tendo sido realizado o interrogatório do réu (eDoc. 84). Os termos de audiência, bem como a gravação dos respectivos atos, foram disponibilizados nos autos pela Secretaria Judiciária (eDocs. 82 e 85).

Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República. A defesa requereu a juntada de documentação complementar (eDocs. 89-91).

Não há dúvida, ainda, de que foi franqueado à defesa acesso, na íntegra, aos elementos de prova constantes dos autos, o que permitiu-lhe o exercício da ampla defesa, com possibilidade de inquirição das testemunhas ouvidas, sem qualquer intercorrência.

Ressalte-se, ainda, que a defesa não apontou qualquer fato específico que poderia, eventualmente, caracterizar comprometimento ao devido Processo Legal e desrespeito ao contraditório e ampla defesa.

Do exposto, infere-se que à defesa foi oportunizada a utilização das faculdades processuais que asseguram a sua efetiva participação no impulsionamento e desdobramentos do feito, a viabilizar, inclusive, todos os meios legítimos de prova para refutar a tese sustentada pela acusação na denúncia, não prosperando qualquer argumento de cerceamento do exercício daqueles direitos.

Portanto, AFASTO A ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELO CERCEAMENTO DE DEFESA.

3. CONTEXTO DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS: ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E INCITAÇÃO AO CRIME, EQUIPARADA PELA ANIMOSIDADE DAS FORÇAS ARMADAS CONTRA OS PODERES CONSTITUCIONAIS (ART. 286, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP) – CO-AUTORIA DE VICENTE CAVALINI FILHO.

AP 2011 / DF

O Ministério Público imputou ao denunciado **VICENTE CAVALINI FILHO** as condutas de associação criminosa (art. 288, *caput*, do CP) e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do CP), nos termos do art. 69, *caput*, do CP (concurso material), narrando de forma clara, expressa e precisa, o contexto no qual inseridos os eventos criminosos multitudinários.

O Ministério Público sustenta, em alegações finais, a plena caracterização dos delitos multitudinários na presente hipótese, afirmando, em apartada síntese, que os crimes cometidos pelo réu foram resultado da união de indivíduos com o objetivo de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito e de realizar um golpe de Estado.

A associação criminosa, com propósito ilegal amplamente conhecido por seus membros desde o início, incentivava as Forças Armadas a tomar o poder sob a alegação de fraude eleitoral e de exercício arbitrário dos poderes constituídos.

O PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos julgamentos de mérito das APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/1012 e 14/9/2023, 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023, 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 1 1.416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023, de minha relatoria, definiu que a hipótese dos atos antidemocráticos de 8/1/2023 ocorreu em associação criminosa e no contexto de crimes multitudinários ou de multidão.

Como ensinado por NILO BATISTA,

“De índole completamente diversa é a hipótese do chamado crime multitudinário: parte aqui o legislador (art. 65, inc. III, al. e) de noções produzidas pela criminologia positivista a respeito de influências desinibidoras e ativantes que a multidão em tumulto teria sobre o indivíduo; (...) Os crimes plurissubjetivos admitem a participação, devendo-se observar que qualquer auxílio ao fato converte o cúmplice em autor direto” (Concurso de agentes – uma investigação sobre os problemas da autoria e da participação no direito penal brasileiro. 2ªed – São Paulo: Editora Lumen Juris, 2004).

AP 2011 / DF

No mesmo sentido, os ensinamentos de JULIO FABBRINI MIRABETE:

“é possível o cometimento de crime pela multidão delinquente, como nas hipóteses de linchamento, depredação, saque etc. Responderão todos os agentes por homicídio, dano, roubo, nesses exemplos, mas terão as penas atenuadas aqueles que cometerem o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocaram (art. 65, III, e). A pena, por sua vez, será agravada para os líderes, os que promoveram ou organizaram a cooperação no crime ou dirigiram a atividade dos demais agentes (art. 62, I)”. (Manual de Direito Penal: parte geral: arts. 1º a 120 do CP – volume 1/ Julio Fabbrini Mirabete, Renato N. Fabbrini – 34. Ed. – São Paulo, Atlas, 2019, página 234).

Trata-se do mesmo posicionamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em relação aos requisitos necessários para a tipificação dos crimes multitudinários ou de autoria coletiva, pois, ao analisar hipótese de crime de dano qualificado imputado a diversas pessoas pelo fato de haverem depredado as instalações de delegacia policial, em protesto contra a posse de novo titular, decidiu:

“nos crimes multitudinários, ou de autoria coletiva, a denúncia pode narrar genericamente a participação de cada agente, cuja conduta específica é apurada no curso do processo desde que se permita o exercício do direito de defesa” (HC 73638, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Julgamento: 30/04/1996, Publicação: 07/06/1996).

Nesse mesmo sentido: HC 75868, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 10/02/1998, DJ 06-06-2003; HC 73638, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 34/04/1996, DJ 07-06- 96); HC 71899, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 04/04/1995, DJ 02-06-95). É o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

“(...) não é inepta a denúncia, nem se reveste de qualquer

AP 2011 / DF

vício a sentença condenatória nela baseada, se, em se tratando de crime multitudinário, não se descreve a conduta individualizada de cada participante da quadrilha” (REsp n. 128.875/RJ, Rel. Min. Anselmo Santiago, Sexta Turma, julgado em 16/12/1997, DJ de 29/6/1998, p. 340.)

Nesse sentido, destaco o voto do Ministro CRISTIANO ZANIN (AP 1060, de minha relatoria, Sessão Plenária de 13/9/23):

Essa forma de praticar crimes, especialmente na era da internet, está sendo estudada nos mais diversos países e causa enorme inquietude. Tais estudos nos oferecem a ideia de que os crimes praticados por multidões em tumulto indicam a presença de uma espécie de contágio mental que transforma os aderentes em massa de manobra. De fato, uma análise multidisciplinar do tema mostra que no caso das multidões em tumulto diversos fenômenos psicológicos entram em ação para criar uma ideia de sugestibilidade: os componentes da turba passam a exercer uma enorme influência recíproca, desencadeando um efeito manada, apto a gerar o que se chama de desindividualização (ou perda das características individuais), que pode levar à prática de atos ilícitos de enorme gravidade.

No mesmo sentido votou o Ministro LUIZ FUX:

Eu fiz algumas anotações, Senhora Presidente, porque, no meu modo de ver, bastaria acompanhar o voto do Relator, de que efetivamente nós estamos diante de um crime multitudinário. Esses delitos foram praticados por uma multidão espontaneamente organizada no sentido de um comportamento comum contra pessoas e coisas. Eles têm as suas características. O agrupamento de pessoas foi organizado de forma espontânea - falou-se em Festa da Selma -, há liderança e organicidade, que estão sendo apuradas por sua Excelência o Ministro Alexandre de Moraes, e foram impulsionadas pela emoção e pelo tumulto com um objetivo comum.

AP 2011 / DF

Igualmente votou a então Presidente da CORTE, Ministra ROSA WEBER:

Com efeito, sobressai do inventário probatório: (i) agrupamento humano armado, dotado de estabilidade e permanência, (ii) reunido, mediante prévio concerto engendrado nas plataformas de social media, (iii) para praticar uma série indefinida de crimes, (iv) materializados nos ataques ao patrimônio da União e a inúmeros bens tombados, bem como na tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais e de depor o governo legitimamente constituído, expõe a presença dos elementos que compõem a estrutura normativo-típica dos crimes (contra o patrimônio público e contra as instituições democráticas) reportados na peça acusatória.

Dessa maneira, assiste inteira razão ao Ministério Público em relação a co-autoria em crimes multitudinários praticada por VICENTE CAVALINI FILHO aos crimes de associação criminosa e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais, no contexto dos crimes multitudinários, pois em crimes dessa natureza, a individualização detalhada das condutas encontra barreiras intransponíveis pela própria característica coletiva da conduta, não restando dúvidas, contudo, de que TODOS contribuem para o resultado, eis que se trata de uma ação conjunta, perpetrada por inúmeros agentes, direcionada ao mesmo fim, conforme já reconhecido pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no momento do recebimento da denúncia:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.

AP 2011 / DF

(...)

5. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.

6. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, conseqüentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.

(INQ 4.921 RD-septingentésimo quinquagésimo nono, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 16/5/2023 a 22/5/2023)

As co-autorias nos crimes de associação criminosa (CP, art. 288, caput) e incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (CP, art. 286, parágrafo único), em situações absolutamente idênticas, FORAM CONFESSADAS por, ao menos, 443 réus que encontram-se na mesma situação de VICENTE CAVALINI FILHO e realizaram ANPP - Acordo de Não Persecução Penal - com a Procuradoria-Geral da República, comprometendo-se a:

(i) prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150 (cento e cinquenta) horas;

(ii) participar presencialmente de curso com a temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12 (doze) horas;

(iii) abster-se de participar de redes sociais abertas;

(iv) cessar todas as práticas delitivas objeto da

AP 2011 / DF

presente ação penal, não sendo processado por outro crime ou contravenção penal; e

(v) adimplir prestação pecuniária, cujo valor foi fixado em, até, R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Não há dúvidas, portanto, sobre a consumação dos delitos praticados em co-autoria por **VICENTE CAVALINI FILHO**.

4. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, *CAPUT*, DO CÓDIGO PENAL)

Dispõe a norma penal do artigo 288, *caput*, do Código Penal:

Associação Criminosa

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

O Ministério Público, em suas alegações finais, sustenta que, embora não seja possível precisar o momento exato em que houve a adesão, ou a associação, para a prática de crimes, é certo que ela se deu anteriormente ao dia 8 de janeiro de 2023.

O acampamento montado em frente aos Quartéis-Generais, mais especificamente o situado em Brasília/DF, apresentava uma complexa e engenhosa organização, demonstrando a estabilidade e a permanência da associação, pressuposto do tipo objetivo.

Conforme demonstrado pela PGR, o propósito criminoso era plenamente difundido e conhecido anteriormente, tendo em vista que os manifestantes insuflavam as Forças Armadas à tomada do poder.

Há diversos registros, inclusive, como apontado pela PGR, sobre a estrutura e a organização observadas no acampamento montado no QGEx, comprovando a materialidade do delito de associação criminosa, conforme detalhado nas alegações finais apresentadas pelo Ministério Público:

O delito de associação criminosa tutela a paz pública e

AP 2011 / DF

constitui crime formal, de consumação antecipada. Sua configuração ocorre quando um conjunto de ao menos três pessoas se reúne com a finalidade de praticar número indeterminado de crimes, que não precisam se consumir. O verbo nuclear do tipo “associar” faz referência a uma reunião não eventual de pessoas, de modo que, para a configuração do tipo, é fundamental que um caráter relativamente duradouro seja verificado no agrupamento.

A consumação do crime é verificada no momento em que ocorre a integração do terceiro sujeito ao grupo, bastando, portanto, que seja praticada a conduta prevista no núcleo do tipo (associar-se), tendo por propósito o fim específico de cometer crimes. Ainda que não seja possível precisar o momento em que o terceiro sujeito aderiu ao grupo, associando-se para a prática de crimes, é certo que referido momento ocorreu anteriormente a 8.1.2023, de modo que a incidência no tipo penal de associação criminosa prescinde da participação efetiva nos atos violentos verificados.

Referida constatação é confirmada pelo fato de o acampamento montado em frente ao Quartel-General do Exército possuir complexa organização, com a distribuição das tendas em setores específicos, sendo destinadas à cozinha e despensa, a medicamentos e atendimento médico e ao fornecimento de energia por geradores. A presença de acesso à internet, informações, local para realização de cultos religiosos e diversas outras organizações internas afasta a tese de ausência de estabilidade e permanência da associação formada.

O insuflamento à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ao golpe de Estado ocorreu de forma constante e reiterada, com a incitação pública à prática de crimes pelos associados, culminando nos crimes multitudinários de 8.1.2023.

A associação atuava dolosamente, unida pelo vínculo subjetivo de sugestão. No ponto, deve ser anotado não ser necessário, para a configuração do vínculo subjetivo, que os agentes se conheçam, bastando a ação por imitação ou sugestão. Referida sugestão deflagradora do comportamento multitudinário iniciou-se antes mesmo de 8.1.2023, sob a forma

AP 2011 / DF

de instigação, replicada instantaneamente por meio de aplicativos de mensagens e redes sociais, almejando a insurgência popular. O fluxo de mensagens e materiais difundidos para arregimentar a multidão fazia expressa referência aos propósitos de “tomada de poder”, em uma investida que “não teria dia para acabar”. Não há que se cogitar, assim, em cometimento de somente um ilícito, apto a desconfigurar a associação criminosa em curso.

No mesmo sentido, não é exigido que a conduta de todos seja idêntica, desde que se insira na linha de desdobramento causal dos fatos típicos puníveis. No ponto, a instrução probatória comprovou que o réu aliou-se subjetivamente à associação criminosa (consciência da colaboração e voluntária adesão), com estabilidade e permanência, objetivando a prática das figuras típicas imputadas (finalidades compartilhadas), sendo o resultado produto de uma obra comum. Não há que se falar, portanto, em individualização insuficiente da conduta.

Não importando se a adesão foi anterior ou concomitante à execução do delito, mas, sim, que a conduta praticada por cada agente influencie no resultado criminoso, como ocorreu na espécie. De fato, ainda que o réu tenha chegado ao acampamento em momento posterior à sua criação, o mero fato de ter aderido subjetivamente ao propósito ilícito difundido pela estrutura é suficiente para a configuração do tipo penal. No ponto, a presença de câmeras no local não afasta os elementos do tipo do crime multitudinário.

Quanto ao vínculo de natureza psicológica (subjetiva), importa consignar que são puníveis os agentes que agem e concorrem, voluntária e conscientemente, para produzir a obra comum. Não se exige, porém, prévio acordo ou entendimento recíproco, bastando que as vontades ou representações do resultado estejam encadeadas por meio de um liame de ordem subjetiva. Da análise dos autos, é possível reconhecer que o grupo criminoso, e especificamente ao réu, agia com o conhecimento de que cada interveniente concorria com a ação de outrem, tendo ciência, ainda, de que contribuía para configurar o fato.

Dessa maneira, com relação aos atos criminosos

AP 2011 / DF

praticados, é inegável a vinculação psicológica dos integrantes da associação, o que é demonstrado pela existência de agrupamento permanente, estável e organizado, com estrutura física montada, em que ideias atentatórias ao Estado Democrático de Direito e aos Poderes Constituídos eram amplamente difundidas.

Sobre os tipos penais imputados ao acusado, o Ministério Público prosseguiu, ressaltando que o crime de associação criminosa, ao tutelar a paz pública, é crime formal de consumação antecipada, configurado quando três ou mais pessoas se reúnem com a intenção de cometer crimes indeterminados, os quais independem da efetiva consumação.

A associação deve ser duradoura, e o crime se consuma com a adesão do terceiro membro ao grupo, desde que o propósito seja cometer crimes.

Destaca-se, ainda, que a complexa organização do acampamento em frente ao Quartel-General do Exército, com setores específicos para diversas necessidades, demonstra a estabilidade e permanência ínsitos da associação criminosa, o que é o suficiente para a necessária subsunção do fato à norma, em juízo de materialidade delitiva.

Colhe-se, por outro lado, da ampla instrução processual levada a efeito, assim como da manifestação ministerial, que a incitação à abolição do Estado Democrático de Direito e ao golpe de Estado eram constantes, de modo a culminar, inclusive, nos crimes cometidos no fatídico 8 de janeiro de 2023.

Tem-se, ainda, que a associação criminosa atuava dolosamente, unida por um vínculo subjetivo de sugestão, não se exigindo que todos os agentes se conhecessem, haja vista que as ações, no contexto de crimes desse jaez, ocorrem por imitação ou sugestão. Certo é, aliás, que a instigação catalizadora da associação criminosa iniciou-se em data anterior a 8 de janeiro de 2023, por meio de mensagens e redes sociais, com a conclamação popular pela tomada do poder.

No caso dos autos, consoante já destacado, a prova produzida demonstrou que o réu associou-se voluntariamente à associação criminosa com estabilidade e permanência, visando às finalidades ilícitas compartilhadas. A adesão do réu ao propósito ilícito da associação é suficiente para a configuração do crime, independentemente do momento em que se fixou no acampamento.

O vínculo subjetivo (psicológico) implica que todos os agentes, agindo voluntária e conscientemente, contribuem para o resultado criminoso. Não é

AP 2011 / DF

necessário prévio acordo, bastando o encadeamento das vontades. A análise dos autos confirma, em suma, que o grupo agia com conhecimento mútuo das ações e consequências.

Registre-se, nesse contexto, trecho de voto da Ministra Rosa Weber, na AP 1060 (Sessão Plenária de 13/9/23), elucidativo dos elementos aptos a configurar o crime de associação criminosa:

Com efeito, sobressai do inventário probatório: (i) agrupamento humano armado, dotado de estabilidade e permanência, (ii) reunido, mediante prévio concerto engendrado nas plataformas de social media, (iii) para praticar uma série indefinida de crimes, (iv) materializados nos ataques ao patrimônio da União e a inúmeros bens tombados, bem como na tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito – impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais – e de depor o governo legitimamente constituído, expõe a presença dos elementos que compõem a estrutura normativo-típica dos crimes (contra o patrimônio público e contra as instituições democráticas) reportados na peça acusatória.

Em seu interrogatório policial, o acusado **VICENTE CAVALINI FILHO CONFESSOU** ter deixado sua cidade de residência, em Doutor Camargo/PR, para participar de movimento político na cidade de Brasília, tendo salientado, ainda, pernoite junto ao acampamento em frente ao Quartel-General do Exército, onde permaneceu de 8 a 9 de janeiro de 2023, até ser preso pela Polícia Federal:

QUE chegou ontem, domingo, por volta de 15h em Brasília - DF; QUE veio em um ônibus saído do Tiro de Guerra, QG de Maringá - PR; QUE veio apenas para o acampamento no QG do Exército; QUE quando chegou ao acampamento, o mesmo estava bastante vazio porque a maioria das pessoas já tinha saído para a manifestação na Praça dos Três Poderes; QUE nesse momento também se deslocou até a Praça dos Três Poderes; QUE subiu no prédio do Congresso Nacional; QUE apenas subiu no edifício mas não destruiu nem participou de nenhum tipo de depredação.

AP 2011 / DF

QUE apenas subiu no Congresso Nacional; QUE ficou perto dos pratos das Casas QUE ficou ali por cerca de meia hora; QUE não conhece lideranças do movimento; QUE conhecia naquele cenário apenas alguns colegas que tinham vindo de Maringá-PR; QUE sequer sabe nome dessas pessoas; QUE foram apenas companheiros de viagem de ônibus.

Apesar de ter exercido o direito ao silêncio no interrogatório judicial (eDoc. 84), os elementos de prova colhidos na instrução processual demonstram que **a confissão do réu, no interrogatório policial, é corroborada por, ao menos, 443 réus co-autores dos crimes que, igualmente, confessaram a mesma conduta e firmaram ANPPs com a Procuradoria-Geral da República, devidamente homologados por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.**

Ressalta-se, ainda, que o Laudo nº 2549/2024 - INC/DITEC/PF - laudo de perícia criminal referente ao exame do telefone celular do réu, verificou que foram *“encontrados alguns arquivos de foto e de vídeo criados pelo usuário em 08/01/2023”* (eDoc. 129, fl. 8). Dentre esses arquivos, verifica-se a presença de VICENTE CAVALINI FILHO com os demais réus co-autores, em Brasília:



AP 2011 / DF

Destaca-se, ainda, os registros de VICENTE CAVALINI FILHO em direção ao Congresso Nacional, com os prédios da Câmara dos Deputados e do Senado Federal:

LAUDO Nº 2549/2024- INC/DITEC/PF



Figura 04 – Exemplos de imagens recuperadas do cache da galeria.

O laudo pericial corrobora a presença do réu em claro caráter associativo com as demais pessoas com a finalidade de praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito. A perícia elaborada pela Polícia Federal demonstra que VICENTE CAVALINI FILHO participou de forma deliberada e consciente dos atos ilícitos praticados, principalmente no Congresso Nacional.

Nesse sentido, não merece prosperar a tese defensiva de que o réu

AP 2011 / DF

“jamais esteve acampado em frente ao Quartel General de Brasília, não havendo qualquer espécie de permanência em sua conduta” (eDoc. 111, fl. 14).

O Laudo nº 2549/2024 - INC/DITEC/PF informou a existência de *“dados de geolocalização no período de 06 a 08 de janeiro de 2023 encontrados foram extraídos e exportados para as ferramentas gráficas de pesquisa e análise disponíveis no apêndice digital que é parte integrante deste laudo”* (e Doc. 129, fl. 11). Nota-se, que no dia 8/1/2023, o réu esteve em Brasília, inclusive tendo estado no acampamento detalhado na denúncia (eDoc. 129, fl. 11):

34	08/01/2023 12:51:24(UTC-3)	-15.781790, -47.924418	Quarta Avenida, Brasília - Federal District, 73340, Brazil	Other Party Visited	WhatsApp	554488533023@s.whatsapp.net
35	08/01/2023 12:51:24(UTC-3)	-15.781790, -47.924418	Quarta Avenida, Brasília - Federal District, 73340, Brazil	Other Party Visited	WhatsApp	554488533023@s.whatsapp.net
36	08/01/2023 13:05:48(UTC-3)	-15.780400, -47.921900	N1, Brasília - Federal District, 73340, Brazil	Visited	Google Photos	
37	08/01/2023 13:23:00(UTC-3)	-15.778400, -47.921900	Avenida do Exército, Brasília - Federal District, 70630-000, Brazil	Visited	Google Photos	
38	08/01/2023 14:36:28(UTC-3)	-15.794206, -47.891573	SHS Quadra 5, 4, Brasília - Federal District, 70346-090, Brazil	Shared	WhatsApp	554488533023@s.whatsapp.net
39	08/01/2023 15:28:20(UTC-3)	-15.798300, -47.866500	Alameda dos Estados, Q103, Praça Portugal, Brasília - Federal District, 73340, Brazil	Visited	Google Photos	
40	08/01/2023 15:29:03(UTC-3)	-15.798300, -47.866500	Alameda dos Estados, Q103, Praça Portugal, Brasília - Federal District, 73340, Brazil	Visited	Google Photos	
41	08/01/2023 20:31:23(UTC-3)	-15.773808, -47.922219	Edif Avenida Do Exército, Brasília - Federal District, 73340, Brazil	Other Party Visited	WhatsApp	554488533023@s.whatsapp.net
42	08/01/2023 20:31:23(UTC-3)	-15.773808, -47.922219	Edif Avenida Do Exército, Brasília - Federal District, 73340, Brazil	Other Party Visited	WhatsApp	554488533023@s.whatsapp.net
43	08/01/2023 20:33:18(UTC-3)	-15.772832, -47.922762	Edif Avenida Do Exército, Brasília - Federal District, 73340, Brazil	Other Party Visited	WhatsApp	554488533023@s.whatsapp.net
44	08/01/2023 20:33:18(UTC-3)	-15.772832, -47.922762	Edif Avenida Do Exército, Brasília - Federal District, 73340, Brazil	Other Party Visited	WhatsApp	554488533023@s.whatsapp.net
45	08/01/2023 20:33:21(UTC-3)	-15.772826, -47.922787	Edif Avenida Do Exército, Brasília - Federal District, 73340, Brazil	Other Party Visited	WhatsApp	554488533023@s.whatsapp.net
46	08/01/2023 20:33:21(UTC-3)	-15.772826, -47.922787	Edif Avenida Do Exército, Brasília - Federal District, 73340, Brazil	Other Party Visited	WhatsApp	554488533023@s.whatsapp.net
47	08/01/2023 21:09:30(UTC-3)	-15.794461, -47.890978	SHS Quadra 5, 4, Brasília - Federal District, 70322-908, Brazil	Other Party Visited	WhatsApp	554488533023@s.whatsapp.net
48	08/01/2023 22:07:08(UTC-3)	-15.772547, -47.920405	Avenida do Exército, 11, Brasília - Federal District, 70630-000, Brazil	Other Party Visited	WhatsApp	554488533023@s.whatsapp.net
49	08/01/2023 22:07:08(UTC-3)	-15.772547, -47.920405	Avenida do Exército, 11, Brasília - Federal District, 70630-000, Brazil	Other Party Visited	WhatsApp	554488533023@s.whatsapp.net

Figura 05 – Dados de geolocalização entre os dias 06/01/2023 e 08/01/2023.

Pontua-se, por exemplo, que os dados de geolocalização demonstram que o réu esteve na Avenida do Exército, localização do acampamento em frente ao Quartel General, às 13h23, assim como a partir das 20h31 até às 22h07. O laudo pericial ainda conclui pela presença do réu no Distrito Federal, o que reforça a imputação da Procuradoria-Geral da República.

Apesar de o acusado ter juntado documentação referente à *“compras e eventos ocorridos entre os dias 31.10.2022 e 5.1.2023”* (eDoc. fl. 14), constata-se que tais elementos de prova não demonstraram a sua inocência. Ao contrário, a documentação anexada pela Defesa do réu sugere que VICENTE CAVALINI FILHO trabalhou até o dia 5/1/2023, de modo que os dados de geolocalização evidenciam a

AP 2011 / DF

presença de VICENTE CAVALINI FILHO no acampamento, em frente ao Quartel General do Exército.

Os elementos de prova colhidos na instrução processual com a plena observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa comprovam que o réu integrou a associação criminosa, tendo participado ativamente com a finalidade de praticar crimes visando a subversão do Estado Democrático de Direito.

Nesse contexto, inclusive, destaquem-se os relatos das testemunhas, em especial do CeIPM CARLOS EDUARDO MELO DE SOUZA, que destacou que, no final do dia 9 de janeiro, foi até o acampamento, podendo constatar uma estrutura bem organizada, com barracas, lonas, alimentos estocados, água, geradores, eletrodomésticos, tais como geladeiras e freezers.



AP 2011 / DF

Consoante já ressaltado, a análise das condutas perpetradas não pode ser dissociada da associação criminosa que acarretou na barbárie presenciada no dia 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, sendo de se destacar que o bando golpista encontrava-se extremamente organizado e com tarefas bem definidas, cabendo ao acusado, no caso, a permanência junto ao acampamento golpista de modo a incitar a prática de crimes por terceiros pessoas, assim como a animosidade entre as Forças Armadas e os Poderes Republicanos devidamente constituídos, sendo o que basta para a materialidade dos delitos de associação criminosa e incitação ao crime.

A narrativa das testemunhas ratifica, em uníssono, o intuito comum à atuação da horda golpista, extremamente organizada e efetiva do acusado **VICENTE CAVALINI FILHO** ao se credenciar para fazer parte do acampamento montado em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília/DF.

Na presente ação penal, portanto, constata-se a comprovação, acima de qualquer dúvida razoável, da aderência do acusado à turba

AP 2011 / DF

golpista, apta a comprovar seu elemento subjetivo do tipo – DOLO – para a prática do crime imputado pela Procuradoria-Geral da República e previsto no artigo 288, *caput*, do Código Penal (associação criminosa).

A conclusão referida é reforçada pelo fato de que, mesmo após o dia 8 de janeiro de 2023, o acusado **VICENTE CAVALINI FILHO**, permanecia no acampamento golpista, montado em frente ao Quartel-General do Exército, de modo a manter vivo o movimento desordeiro e a busca por um golpe de Estado, até sua detenção pela Polícia Militar do Distrito Federal.

Diante de todo o exposto, CONDENO o réu VICENTE CAVALINI FILHO pela prática do crime previsto no art. 288, *caput*, do Código Penal (associação criminosa).

5. INCITAÇÃO AO CRIME EQUIPARADA PELA ANIMOSIDADE DAS FORÇAS ARMADAS CONTRA OS PODERES CONSTITUCIONAIS (ART. 286, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL).

Dispõe a norma penal:

Incitação ao crime

Art. 286 – Incitar, publicamente, a prática de crime:

Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem incita, publicamente, animosidade entre as Forças Armadas, ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade.

A previsão constitucional do Estado Democrático de Direito consagra a obrigatoriedade de o País ser regido por normas democráticas, com observância da Separação de Poderes, bem como vincula a todos, especialmente as autoridades públicas, ao absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais, com a finalidade de afastamento de qualquer tendência ao autoritarismo e à concentração de

AP 2011 / DF

poder.

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, artigos 5º, XLIV, e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações públicas visando à ruptura do ESTADO DE DIREITO, através da extinção das cláusulas pétreas constitucionais, dentre elas a que prevê a Separação de Poderes (CF, artigo 60, § 4º), com a consequente instalação do arbítrio.

Não é qualquer manifestação crítica que poderá ser tipificada pela presente imputação penal, pois a liberdade de expressão e o pluralismo de ideias são valores estruturantes do sistema democrático, merecendo a devida proteção. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva.

Contudo, tanto são inconstitucionais as condutas e manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático, quanto aquelas que pretendam destruí-lo, juntamente com suas instituições republicanas, pregando a violência, o arbítrio, o desrespeito à Separação de Poderes e aos direitos fundamentais, em suma, pleiteando a tirania, o arbítrio, a violência e a quebra dos princípios republicanos, como se verifica pelas manifestações criminosas ora imputadas ao denunciado.

Não existirá um ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO sem que haja Poderes de Estado, independentes e harmônicos entre si, bem como previsão de Direitos Fundamentais e instrumentos que possibilitem a fiscalização e a perpetuidade desses requisitos; consequentemente, a conduta por parte do réu revela-se gravíssima e corresponde aos preceitos primários estabelecidos nos indigitados artigos do nosso Código Penal.

O teor do movimento golpista que culminou nos ataques aos edifícios-sede dos Poderes variava entre ataques antidemocráticos às instituições constituídas, em especial ao Poder Judiciário, com reiterados pedidos de fechamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e a conclamação das Forças

AP 2011 / DF

Armadas para que promovessem uma intervenção militar, e a deposição do Governo legitimamente eleito.

Trata-se do tipo penal inserido pela Lei 14.197/21 que abriu novo Título no Código Penal com vistas a proteger o bem jurídico previsto no artigo vestibular da Constituição e objeto de mandado de criminalização previsto no seu art. 5º, XLIV. Isso porque os Crimes contra o Estado Democrático de Direito trazem uma noção de proteção de bem jurídico fundamental e não simplesmente a tutela da segurança nacional.

O tipo penal consagra um instrumento protetivo do Estado Democrático de Direito, como ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“(...) o Estado Democrático de Direito precisa contar com instrumentos legais para combater atividades ilegais, que considerem meios alternativos e violentos para chegar ao poder. Por isso, para assegurar a soberania, o poder nas mãos do povo, exercido pelo pluralismo político, além de garantir a defesa da paz, repudiando atos de grupos armados avessos à democracia”. (Código Penal Comentado, 23ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 1503).

A legislação estabeleceu a tipificação desse crime, como absolutamente necessário à preservação do Estado Democrático de Direito e de suas Instituições previstas na Constituição Federal, como bem ressaltado nas alegações finais apresentadas pela Procuradoria-Geral da República:

O delito de incitação ao crime, por sua vez, envolve a apologia pública de condutas criminosas, tendo como sujeito passivo a sociedade como um todo, por colocar em risco a segurança da coletividade. Sua consumação ocorre a partir da exteriorização da incitação com alcance público, com dolo livre e consciente. A incitação pública de animosidade entre as Forças Armadas, ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade, deve ter potencialidade para alcançar o resultado almejado, para que, então, possa ser gerada a responsabilização.

O movimento ao qual o réu aderiu possuía significativo grau de lesividade, ao clamar por uma ruptura constitucional

AP 2011 / DF

que resultasse em tomada de poder pelas Forças Armadas. Tamanho movimento, iniciado na propagação de mensagens de teor antidemocrático mediante redes sociais e que tomou forma concreta na montagem de acampamento em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília, foi elemento essencial na sequência de eventos que resultaram no 8.1.2023. De fato, o cenário de destruição registrado em 8.1.2023 não prescindiu de apoio físico e intelectual fornecido pela incitação ao crime constante, verificada no acampamento.

Nesse sentido, os atos praticados pelo réu resultaram em dano concreto à segurança nacional e ao regime representativo e democrático. Na espécie, a participação do réu, de forma estável e permanente, no acampamento localizado em frente ao Quartel-General do Exército, incitando publicamente a prática de atos que buscavam a abolição do Estado Democrático de Direito e a destituição do governo legitimamente eleito, permitem o enquadramento de sua conduta nos termos do art. 268, parágrafo único, do Código Penal. O réu, ao declarar que os presentes no acampamento portavam faixas com os dizeres “nosso Brasil será liberto”, deixou clara sua adesão consciente à conduta daqueles que, de forma contínua, incitaram os atos que resultaram no 8.1.2023, razão pela qual não pode alegar ausência de dolo quanto ao resultado alcançado pelo grupo ao qual se associou.

No ponto, de forma a reiterar a sua adesão à finalidade antidemocrática, mesmo após os atos de 8.1.2023, o réu permaneceu acampado em frente ao Quartel-general em Brasília, o que resultou em sua prisão em flagrante em 9.1.2023.

O Ministério Público narra, ainda, que, entre outros crimes, os manifestantes, por meio de cartazes e *banners* pretendiam criar clima de animosidade e desconfiança das Forças Armadas em relação ao demais Poderes Republicanos, incluindo o governo legitimamente constituído. Isso porque do fluxo de mensagens e materiais difundidos das redes sociais fica claro que a intenção não era apenas impedir o exercício dos Poderes constituídos, mas a “**tomada de poder**”, em uma investida que “**não teria dia para acabar**”:

AP 2011 / DF

Os extremistas buscavam gerar o caos para obrigar as Forças Armadas, ante a interpretação deturpada do art. 142 da Constituição e do Decreto 3.897/2001, na edição de decreto para a garantia da lei e da ordem, com a assunção das funções dos Poderes constituídos.

Portanto, o insuflamento, que visava à prática de outros crimes, também objetivava criar clima de animosidade e desconfiança entre as Forças Armadas e os demais poderes, em especial o Legislativo e o Judiciário, visando, evidentemente, tanto à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, quanto à deposição de governo legitimamente eleito, em meio a um golpe de Estado, fato que denota desígnio criminoso autônomo na mesma empreitada criminosa.

O acusado **VICENTE CAVALINI FILHO** foi detido e conduzido à Polícia Federal, em 9 de janeiro de 2023, no interior do acampamento montado em frente ao Quartel General do Exército em Brasília.

As testemunhas apontam que o réu, assim como diversas outras pessoas, se encontrava em um acampamento situado em frente ao Quartel-General do Exército, nesta cidade de Brasília/DF.

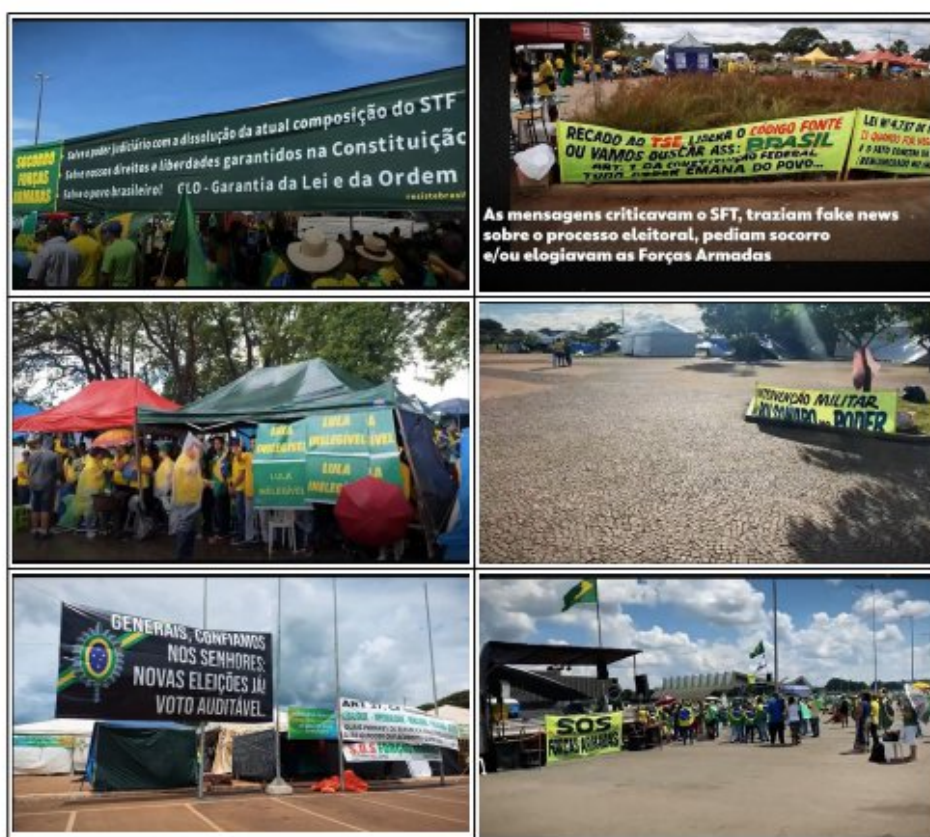
Ressalte-se, novamente, a declaração do réu, em seu interrogatório, de que foi a Brasília para conhecer e fazer parte dos acampamentos, nos quais havia diversas faixas de teor antidemocrático, o que demonstra sua adesão consciente à conduta perpetrada.

Sobre o acampamento, ficou exaustivamente demonstrado, quer por meio das imagens que acompanharam a denúncia, quer por meio do testemunho prestado, tratar-se de local extremamente organizado (contando, inclusive, com gerador de energia elétrica), dotado de autêntica divisão de tarefas e funções (barracas destinadas ao carregamento de aparelhos de telefonia celular, barracas destinadas ao entretenimento de crianças, barracas destinadas à distribuição de comida, barracas destinadas à distribuição de água, barraca destinada a atendimentos de saúde, barraca destinada à atividade de massoterapia, barraca destinada ao recebimento de doações, entre outras). Observou-se, ademais, a existência de diversas faixas e *banners* com dizeres relacionados a temas políticos, envolvendo o ex-Presidente da República

AP 2011 / DF

e o atual, restando evidenciado o intuito de provocar animosidade entre as Forças Armadas e os demais Poderes da República (conclamando a operação de Garantia da Lei e da Ordem, a novas eleições e a intervenção militar nesse sentido, fls. 07 do eDoc. 01).

O crime de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais foi consumado, com dolo livre e consciente do réu, com a exteriorização pública da incitação às Forças Armadas para romper a ordem constitucional, o que revelou-se essencial e determinante para os eventos de 8 de janeiro de 2023.



Observe-se, ainda, que, mesmo após os atos de 8 de janeiro de 2023, o réu permaneceu no acampamento, resultando em sua prisão em flagrante em 9 de janeiro de 2023, o que reforça a demonstração de sua adesão à finalidade golpista e antidemocrática, que visava à abolição do Estado de Direito.

Portanto, inequívoca a comprovação de que o réu aderiu à turba golpista que se encontrava em frente ao Quartel-General do Exército,

AP 2011 / DF

pleiteando um golpe de Estado com intervenção militar e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de modo a levar ao fechamento dos poderes constituídos, tudo com base em leitura totalmente equivocada e deturpada do art. 142 da Constituição Federal, de modo a forçar as Forças Armadas, submetidas ao Presidente da República, a ir de encontro a sua missão constitucional.

A participação ativa do réu na dinâmica golpista, portanto, ficou amplamente comprovada, assente de qualquer dúvida, por meio de seu interrogatório judicial e o teor do depoimento das testemunhas em juízo inquiridas, consumando a infração penal prevista no artigo art. 286, parágrafo único, do Código Penal.

Diante de todo o exposto, CONDENO o réu VICENTE CAVALINI FILHO pela prática do crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

6. DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO PENAL PARA CONDENAR O RÉU VICENTE CAVALINI FILHO nas penas dos artigos 286, parágrafo único, (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e 288, *caput* (associação criminosa), na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

7. DOSIMETRIA DA PENA

Passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, de acordo com o critério trifásico descrito no art. 68 do Código Penal.

A dosimetria da pena deve levar em conta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal em relação a cada caso concreto, de acordo com suas circunstâncias, pois encerra certa discricionariedade judicial para a sua efetivação, não havendo critérios matemáticos que vinculem o número de vetores positivos ou negativos previsto no referido

AP 2011 / DF

artigo, com bem destacado pela eminente Min. ROSA WEBER:

“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC 132.475 AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 23/8/2016).

A identificação de circunstância desfavorável ao réu, a depender de sua gravidade, pode ensejar um acréscimo mais intenso na pena do que a presença, em outro contexto, de duas ou mais vetoriais negativas, que, no entanto, inspiram, em seu conjunto, menor grau de censurabilidade. Nesse sentido, o Min. EDSON FACHIN, em voto proferido na AP 863/SP, julgada pela Primeira Turma em 23/5/2017, assinalou que:

“(...) a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena-base.”

Nesse mesmo sentido: TPA 5, Rel. Min. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe. 21/03/2019; AP 971, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe. 11/10/2016; AP 644 ED-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe. 21/02/2019; HC 99.270, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe. 09/10/2015; RHC 128.355, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe. 24/10/2017; RHC 152.050 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe. 28/05/2018; HC 107.409, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe. 10/05/2012; HC 132.475 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe. 23/08/2016.

Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC 166.548 MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe. 19/12/2018; HC 206.750, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe. 01/10/2021; RHC 152.036, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe. 08/02/2018; ARE 1.224.175, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe. 2/9/2019; HC 208.353, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe. 17/11/2021; RHC 212.338, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe. 9/3/2022.

AP 2011 / DF

Assim, para a fixação da PENA BASE, no caso concreto, em atenção às circunstâncias do **artigo 59 do Código Penal**, tais como culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, não se observam, objetivamente consideradas, elevada extrapolação dos elementos próprios aos ilícitos penais praticados, de modo que possível a fixação da pena base no mínimo legal.

A análise dos autos não demonstra existir quaisquer das condições de culpabilidade desfavorável ao réu.

Passo, portanto, à análise das demais etapas da fixação de pena para cada infração penal.

7.1) art. 288, *caput*, do Código Penal (Associação Criminosa)

Dispõe a norma penal do artigo 288, *caput*, do Código Penal:

Associação Criminosa

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Com base na inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base mínima em 1 (um) ano de reclusão.

Não se observam, ainda, circunstâncias agravantes a serem reconhecidas, sendo de se ressaltar que, embora presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea e, do Código Penal (ter o agente cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não a provocou), esta não pode resultar em pena aquém do mínimo legal.

Nesse sentido, o Tema 158 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ("*Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal*"), fixado no julgamento do RE 597.270 QO-RG, Relator Ministro CEZAR PELUSO, j. 26/3/2009.

Pena definitiva. Ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição, torno a **pena mínima em definitiva em 1 (um) ano de reclusão.**

7.2) art. 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao

AP 2011 / DF

crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

Dispõe a norma penal:

Incitação ao crime

Art. 286 – Incitar, publicamente, a prática de crime:

Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem incita, publicamente, animosidade entre as Forças Armadas, ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade.

Com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente analisadas, deixo de fixar a pena privativa de liberdade para fixar exclusivamente a **pena de multa**, medida, esta, socialmente recomendável, sendo adequada e suficiente para a repressão do delito.

Nos termos do artigo 49 do Código Penal, “*a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa*”, sendo este estabelecido “*no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa*”.

Nesse contexto, portanto, verifica-se que, como forma de se atender às finalidades da sanção penal, dentre as quais a retributiva, a preventiva e a ressocializadora, suficiente a fixação da multa em **20 (vinte) dias-multa**, sendo o **valor unitário** fixado em **1/2 (meio) salário mínimo nacional**.

Pena definitiva. Torno a **pena de multa definitiva em 20 (vinte) dias-multa, fixado o valor unitário em (1/2) meio salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.**

8. TOTAL DAS PENAS E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO.

Consideradas as penas para cada crime acima fixadas, e a

AP 2011 / DF

existência de concurso material (CP, art. 69), FIXO A PENAL FINAL do réu VICENTE CAVALINI FILHO, em relação ao crime do artigo 288 do Código Penal, em 1 (um) ano de reclusão, e, em relação ao crime do artigo 286, parágrafo único, do Código Penal, no pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixado o valor unitário em 1/2 (meio) salário mínimo nacional, à época dos fatos.

No caso dos autos, observa-se que o réu **VICENTE CAVALINI FILHO** foi condenado, por crime doloso, a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, de modo que, nos termos do art. 33, §§ 2º, 'a', e 3º, do Código Penal, fixo o regime **aberto** para o início do cumprimento da reprimenda no tocante ao crime previsto no artigo 288 do CP.

Observo, ademais, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, haja vista o montante de pena aplicável, tratando-se de medida socialmente recomendável.

Nestes termos, portanto, **substituo a pena privativa de liberdade fixada por restritivas de direitos**, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentos e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre "*Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado*", com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;

AP 2011 / DF

(vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente.

Havendo descumprimento injustificado da penas substitutivas impostas, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 5º, do Código Penal.

9. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA (ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). FIXAÇÃO DE MONTANTE A TÍTULO DE DANOS MORAIS COLETIVOS, EM FAVOR DO FUNDO PREVISTO NO ARTIGO 13 DA LEI 7.347/1985.

A Procuradoria-Geral da República apresentou pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização mínima, conforme artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, a título de danos morais coletivos evidenciados pela prática dos crimes objeto da denúncia.

Os eventos descritos na denúncia, relacionados aos acampamentos golpistas montados em frente ao Quartel-General do Exército, resultaram em significativos prejuízos financeiros tanto para os cofres públicos quanto para a população em geral. Segundo informações reveladas pela imprensa (<https://www.metropoles.com/distrito-federal/exercito-gastou-quase-r-400-mil-durante-atos-golpistas-no-qg-de-brasilia>), o Exército Brasileiro gastou quase R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em operações de segurança e manutenção da ordem no entorno dos acampamentos. Esses gastos, que envolvem não apenas a presença de forças de segurança, mas também operações logísticas e de apoio, para manutenção da ordem, representam um ônus significativo ao erário público, haja vista que referido montante poderia ser direcionado a políticas públicas essenciais em prol da população brasileira.

Além do gasto com segurança, os dispêndios relativos à limpeza urbana, nos dias que se seguiram à desocupação dos acampamentos, merece destaque, na medida em que, conforme noticiado (<https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2023/01/09/slu-recolhe-60-toneladas-de-lixo-de-acampamento-no-qg-do-exercito-em-brasilia.ghtml>), o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal recolheu 60 toneladas de resíduos, gerando custos elevados, que envolveram não apenas a utilização de quinze caminhões de lixo, como também a utilização de trabalhadores que

AP 2011 / DF

poderiam ser alocados em outras atividades, além de aumentar riscos com a saúde pública e a propagação de doenças.

Quanto ao ponto, dispõe o art. 91, inciso I, do Código Penal:

“São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime”.

Já o art. 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que:

“O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.

A necessidade de indenização pelos danos morais advindos da prática dos crimes é indiscutível nos autos, haja vista o prejuízo difuso e coletivo causado pela ação da horda golpista, que visava à ruptura institucional, com a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente eleito, mediante violência, vandalismo e significativa depredação ao patrimônio público. Certo é, ainda, que referida horda já se encontrava em acampamentos espalhados pelo país – o que inclui o acampamento localizado em frente ao Quartel-General do Exército – desde a proclamação do resultado das Eleições Gerais de 2022.

Sobre dano moral coletivo, merece destaque a lição de Carlos Alberto Bittar Filho:

“Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na

AP 2011 / DF

seara de dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (*damnum in re ipsa*)” (Dano moral coletivo no atual contexto brasileiro. Revista de Direito do Consumidor n. 12. São Paulo : Revista dos Tribunais, out-dez, 1994, p. 55).

No caso dos autos, é patente a frontal violação ao dever de observância à Constituição Federal e a seus valores supremos, calcados no Estado Democrático de Direito, “destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias”.

Conforme destaquei em minha posse na Presidência do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL:

A Democracia não é um caminho fácil, exato ou previsível, mas é o único caminho.

A Democracia é uma construção coletiva daqueles que acreditam na liberdade, daqueles que acreditam na paz, que acreditam no desenvolvimento, na dignidade da pessoa humana, no pleno emprego, no fim da fome, na redução das desigualdades, na prevalência da educação e na garantia da saúde de todos os brasileiros e brasileiras.

A Democracia é uma construção coletiva de todos que acreditam na soberania popular, e mais do que isso, de todos que confiam na sabedoria do povo, que acreditam que nós, autoridades do Judiciário, Executivo e Legislativo, somos passageiros, mas que as Instituições devem ser fortalecidas, pois são permanentes e imprescindíveis para um Brasil melhor, para um Brasil de sucesso e progresso, para um Brasil com mais harmonia, com mais Justiça Social, com mais igualdade e solidariedade, com mais amor e esperança!!!!

Em suma, portanto, é de se destacar que o que pode ser extraído

AP 2011 / DF

do caso presente é o absoluto desrespeito a princípios constitucionais de observância obrigatória, sobre os quais não pode ser admitida qualquer margem ou limite transacional.

Desta forma, restaram configuradas nos autos a materialidade e autoria delitiva, em vista do que emerge como consectário lógico a obrigação de indenização pelos danos decorrentes do delito, conforme art. 91, I, do Código Penal, e art. art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Imprescindível ainda assentar que a sentença ou acórdão penal condenatório, ao fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do CPP), poderá condenar o réu ao pagamento de danos morais coletivos.

Esta SUPREMA CORTE já se manifestou no sentido de que a condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do CPP), podendo incluir nesse montante o valor do dano moral coletivo (STF. 2ª Turma. AP 1002/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 9/6/2020 e AP 1025, Rel. Min. Edson Fachin, julgada pelo Plenário em 1º/6/2023).

No recente julgado do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na mencionada AP 1025, Rel. Min. Edson Fachin, versando caso com reconhecimento de malferimento do patrimônio público a partir das condutas praticadas pelos acusados, cuja inteligência, guardadas as devidas especificidades, pode facilmente ser agora renovada, decidiu-se, a partir da leitura dos art. 5º, X, da Constituição Federal; art. 186 do Código Civil; o art. 6º, VI e VII, do Código de Defesa do Consumidor; do art. 1º, VIII, da Lei n. 7.347/1985, pela demonstração do necessário nexo causal entre a conduta praticada pelos acusados e o dano moral coletivo ocasionado à sociedade brasileira:

“Diante da ofensa a direitos difusos, ou seja, pertencentes a titulares indeterminados, os danos morais coletivos, no caso em análise, têm função eminentemente punitiva, razão pela qual a sua quantificação deve ser guiada primordialmente pelo seu caráter pedagógico, que acolhe tanto a prevenção individual como a geral. “

Por tal razão, fixo como valor mínimo indenizatório a título de danos

AP 2011 / DF

morais coletivos a quantia de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos condenados em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. A referida soma deverá ser corrigida monetariamente a contar do dia da proclamação do resultado do julgamento colegiado, incidindo juros de mora legais a partir do trânsito em julgado deste acórdão.

10. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, **JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR o réu VICENTE CAVALINI FILHO**, em concurso material (CP, art. 69), a:

(1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela **PENA RESTRITIVA DE DIREITOS**, consistente em:

(1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentos e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;

(1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “*Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado*”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;

(1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside até a extinção da pena;

(1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;

(1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do

AP 2011 / DF

Brasil, em nome do condenado;

(1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente.

(2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais);

(3) R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.

Havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 5º, do Código Penal.

Após o trânsito em julgado:

(a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

(b) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas pelo condenado (art. 804 do Código de Processo Penal).

É O VOTO.

19/11/2024

PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 2.011 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
REVISOR	: MIN. NUNES MARQUES
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: VICENTE CAVALINI FILHO
ADV.(A/S)	: LUIZ FERNANDO VILASBOAS
ADV.(A/S)	: RHANA SARAIH MOTA DA SILVA

VOTO

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES (REVISOR): Senhor Presidente, Senhores Ministros, inicialmente, cumprimento o eminente Relator pelo trabalho e pelo voto proferido.

Trata-se de ação penal em que se imputa à parte denunciada a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais), e 288, *caput* (associação criminosa), do Código Penal, observadas as regras do art. 69, *caput* (concurso material), do mesmo diploma.

Os autos foram encaminhados à revisão, nos termos do art. 21, X, do Regimento Interno.

Acolho, assim, o percuciente relatório do ministro Alexandre de Moraes. Passo ao voto.

1. Da incompetência do Supremo para o processamento e julgamento da ação penal

Embora a tese da incompetência do Supremo Tribunal Federal para

AP 2011 / DF

o exercício do juízo de admissibilidade das denúncias apresentadas em razão dos eventos do dia 8 de janeiro de 2023 não tenha sido acolhida nos julgamentos em Plenário Virtual, penso que a questão não precluiu e merece reflexão, debate e enfrentamento aprofundados neste Colegiado, tendo em vista a orientação jurisprudencial em sentido oposto.

Nos votos que proferi ao examinar a admissibilidade de referidas denúncias, sustento que o direito ao juiz natural, previsto no art. 5º, XXXVII e LIII, de nossa Lei Maior, constitui garantia fundamental de que a parte responda perante o juiz competente, limitados os poderes do Estado, que não instituirá juízo ou tribunal de exceção.

Trata-se de garantia fundamental sedimentada nos Estados democráticos de direito ao longo dos últimos séculos.

O juiz natural é aquele regular, prévia e legitimamente investido de jurisdição *in concreto* para o julgamento de determinada demanda, conforme as regras de definição de competência estabelecidas no sistema do direito positivo.

O art. 5º, *caput*, da Constituição Federal de 1988 preconiza que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O mesmo artigo, além de vedar a designação de juízo ou tribunal de exceção (inciso XXXVII), versa, nos termos de seu inciso LIII, que “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”.

Também a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, prevê, no art. 8º, que todo indivíduo tem o direito de ser ouvido por um “juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente pela lei”.

AP 2011 / DF

Nessa linha, o Texto Constitucional confere a determinadas autoridades prerrogativa de foro para o processo penal ou o processo de responsabilidade (arts. 53, § 1º; 86, *caput*; e 102, I, “b” e “c”).

Cumpra assegurar aos acusados o direito de responder ao processo diante da autoridade regularmente investida de jurisdição, de acordo com as regras de competência encerradas na Constituição e na legislação infraconstitucional. É vedada, em consequência, a instituição de juízo posterior ao fato em investigação, **bem assim de juízo universal perante esta Corte Suprema em relação a determinadas classes de crimes e de investigados e réus.**

No plano infraconstitucional, o principal critério para a fixação de competência no processo penal é o do foro do lugar em que a infração houver sido consumada, ou, no caso dos crimes tentados, o do local em que praticado o último ato de execução.

A conexão e a continência – critérios de modificação de competência – e o estabelecimento do juízo preventivo para concentração da jurisdição penal revelam exceções à regra geral de fixação de competência, de sorte que as normas atinentes a esses institutos processuais devem ser interpretadas de forma estrita, não comportando ampliação.

A competência por prerrogativa de função, por sua vez, é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, mas **alcança apenas as pessoas que devem responder perante tais órgãos por crimes comuns e de responsabilidade** (CPP, art. 84).

Nessa perspectiva, o Supremo, debruçando-se sobre o tema, fixou critérios objetivos que vêm sendo adotados para a definição da competência nos processos relativos à denominada Operação Lava Jato, consoante se infere da orientação firmada nos inquéritos de n. 4.130,

AP 2011 / DF

4.244, 4.327 e 4.483, no HC 193.726 (em que fiquei vencido) e nas petições de n. 6.863, 6.727 e 8.090. Entre tais parâmetros, merecem realce os seguintes, extraídos da ementa do acórdão prolatado no Inq 4.130 QO, Plenário, ministro Dias Toffoli, *DJe* de 3 de fevereiro de 2016 – com meus grifos:

(i) “A prevenção, essencialmente, não é um critério primário de determinação da competência, **mas sim de sua concentração, razão por que, inicialmente, devem ser observadas as regras ordinárias de determinação da competência**, tanto *ratione loci* (art. 70, CPP) quanto *ratione materiae*”;

(ii) “A prevenção, nos termos do art. 78, II, ‘c’, do Código de Processo Penal, constitui **critério residual de aferição da competência**”;

(iii) “**Não haverá prorrogação da competência do juiz processante – alargando-a para que conheça de uma causa para a qual, isoladamente, não seria competente –, se não estiverem presentes i) uma das hipóteses de conexão ou de continência (arts. 76 e 77, CPP) e ii) uma das hipóteses do art. 78, II, do Código de Processo Penal**”; e

(iv) “**Nenhum órgão jurisdicional pode-se arvorar de juízo universal** de todo e qualquer crime relacionado a desvio de verbas para fins político-partidários, à revelia das regras de competência”.

Como se vê, a Corte **tem seguido, de forma sistemática, a linha de afastar a tendência de concentração de processos em uma mesma unidade jurisdicional, evitando, assim, dar força atrativa ao foro por prerrogativa de função.**

Pois bem. O eminente Relator concluiu pela competência do Supremo para o exercício do juízo de admissibilidade das denúncias oferecidas nos inquéritos de n. 4.921 e 4.922, bem como para o processamento e julgamento das ações penais delas decorrentes,

AP 2011 / DF

considerado o critério residual da conexão. Invocou, para tanto, os seguintes fundamentos: (i) todas as investigações se referem aos mesmos atos criminosos relacionados à invasão e depredação, em 8 de janeiro de 2023, das sedes do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, o que revelaria **conexão** com as condutas apuradas no âmbito dos procedimentos envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nesta Corte, a exemplo das instauradas contra os deputados federais Clarissa Tércio, André Fernandes, Sílvia Waiãpi e Coronel Fernanda, no âmbito dos inquéritos de n. 4.917, 4.918 e 4.919, a pedido da Procuradoria-Geral da República, e contra o deputado federal Cabo Gilberto Silva, na Pet 10.836; (ii) no Inq 4.781, das “Fake News”, em que apuradas condutas atentatórias à própria Corte Suprema, e no Inq 4.874, no qual se investiga o cometimento, pelas chamadas milícias digitais, de diversas infrações criminais que atentam contra o Estado democrático de direito, há investigados com prerrogativa de foro perante o Supremo – como o senador Flávio Bolsonaro e os deputados federais Otoni de Paula, Cabo Junio Amaral, Carla Zambelli, Bia Kicis, Eduardo Bolsonaro, Filipe Barros, Luiz Phillipe Orleans e Bragança, Guiga Peixoto e Eliéser Girão –, o que igualmente sinalizaria conexão probatória entre o Inq 4.922 e o de n. 4.921.

No que concerne ao primeiro fundamento, com todas as vênias, não identifiquei, no voto proferido pelo Ministro Relator, circunstância concreta a justificar a excepcional atração de competência, por conexão ou continência, para o processamento das investigações e da presente ação penal, em que a parte ré não possui prerrogativa de foro perante este Tribunal, em relação às investigações em curso nas quais envolvidas autoridades aptas a de fato ser aqui julgadas. Seria, aliás, de todo ilógico, do ponto de vista das regras de competência, julgar a ação atraída antes mesmo de apreciar a atratora, ainda em fase de investigação.

A modificação de competência por força da conexão ou continência exige demonstração clara, no plano concreto, à luz de elementos de prova

AP 2011 / DF

colhidos na investigação – os quais devem ser apontados para permitir o controle intersubjetivo da decisão no processo –, de um vínculo probatório ou instrumental. É dizer, há que demonstrar uma linha de continuidade e interligação probatória entre os fatos objeto de investigação no Inq 4.921 e agora em julgamento nesta ação penal.

De acordo com o art. 76 do Código de Processo Penal, a competência será determinada pela conexão:

I – se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;

II – se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;

III – quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

Analisando os autos, não vislumbro, *data venia*, nenhuma dessas hipóteses. Inexiste demonstração de que as infrações atribuídas à parte denunciada teriam sido praticadas em concurso de pessoas com os investigados cujo eventual julgamento deverá ser feito pelo Supremo. De igual forma, não há nas peças acusatórias qualquer elemento concreto a sinalizar que as infrações imputadas teriam sido cometidas a fim de facilitar ou ocultar outras com investigação em curso nos inquéritos de n. 4.917, 4.918 e 4.919, ou mesmo de conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer uma delas. Também não se indicou a forma como as provas dos crimes atribuídos nesta ação influenciariam a produção probatória atinente às infrações **ainda em apuração** nos inquéritos instaurados contra pessoas com foro neste Tribunal.

Ora, não se admite, *permissa venia*, o estabelecimento de conexão

AP 2011 / DF

probatória fundada em presunção abstrata ou inferência extraída de tênues afinidades materiais, sem a indicação de vínculo probatório entre os fatos objeto dos inquéritos atinentes às autoridades com prerrogativa de foro e aqueles atribuídos aos denunciados nos inquéritos de n. 4.922 e 4.921.

Além disso, mesmo quando caracterizada a conexão dos crimes apurados em diferentes inquéritos policiais e ações penais – o que, reitere-se, não veio a ser demonstrado na espécie –, esta Corte tem se orientado pela **adoção, como regra, do desmembramento dos procedimentos formalizados contra coinvestigados ou corréus não detentores de foro por prerrogativa de função, admitindo, excepcionalmente, a atração da competência originária quando verificado que a separação tem potencial de causar prejuízo relevante, passível de aferição em cada caso concreto.** Se não, vejamos:

[...] 1. INQUÉRITOS 4.327 E 4.483. DENÚNCIA. INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EMBARAÇO ÀS INVESTIGAÇÕES RELACIONADAS AO ALUDIDO DELITO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA PROCESSAMENTO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E MINISTROS DE ESTADO. SUSPENSÃO. **DESMEMBRAMENTO QUANTO AOS NÃO DETENTORES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.** AGRAVOS REGIMENTAIS. [...] 5. **DESMEMBRAMENTO DO OBJETO DOS INQUÉRITOS EM RELAÇÃO AOS NÃO DETENTORES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. VIABILIDADE.** 6. PEDIDOS DE TRANCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES E EXCLUSÃO DE NOMES DO ROL DE INVESTIGADOS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. 7. **DESMEMBRAMENTO E REMESSA DOS INQUÉRITOS ÀS INSTÂNCIAS COMPETENTES.**

[...]

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou

AP 2011 / DF

a adotar como regra o desmembramento dos inquéritos e ações penais originárias no tocante a coinvestigados ou corréus não detentores de foro por prerrogativa de função, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a atração da competência originária quando se verifique que a separação seja apta a causar prejuízo relevante, aferível em cada caso concreto. Na espécie, a proposta acusatória afirma a existência de uma única organização criminosa, composta por distintos núcleos operacionais, dentre os quais o integrado por políticos afiliados a diversos partidos. Cuidando a denúncia do núcleo político de organização criminosa composto por integrantes do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) com atuação na Câmara dos Deputados, os autos devem ser remetidos à livre distribuição à Seção Judiciária do Distrito Federal/DF. Em relação ao agravante André Santos Esteves, os autos devem ser direcionados especificamente à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em razão de investigação prévia ali deflagrada. Vencido o relator neste ponto, concernente ao juízo destinatário da remessa, eis que o voto em sua formulação originária (vencida) propôs o envio à 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR. Em observância ao princípio da responsabilidade subjetiva que vigora no ordenamento jurídico-penal pátrio, no que tange à acusação do delito de organização criminosa, caberá ao Ministério Público Federal produzir os elementos de prova capazes de demonstrar, em relação a cada um dos acusados, a perfeita subsunção das condutas que lhes são atribuídas ao tipo penal que tutela o bem jurídico supostamente violado, em especial o seu elemento subjetivo, composto pelo dolo de promover, constituir financiar ou integrar organização criminosa. Por tal razão, o desmembramento não importa em responsabilização indireta dos denunciados em relação aos quais a tramitação da denúncia permanece suspensa neste Supremo Tribunal Federal, não sendo possível falar, ainda, em indissolubilidade das condutas denunciadas. Tendo em vista que o suposto delito de obstrução às investigações relacionadas

AP 2011 / DF

ao crime de organização criminosa teria sido praticado, em grande parte, na Capital Federal, devem os respectivos autos também ser remetidos para processamento perante a Seção Judiciária do Distrito Federal/DF. Agravos regimentais parcialmente providos.

[...]

7. Tratando-se de figura penal dotada de autonomia, o delito de organização criminosa não se confunde com os demais praticados no seu âmbito, **razão pela qual o desmembramento realizado nestes autos não tem o condão de configurar o indevido *bis in idem* em relação a eventuais ações penais ou inquéritos em trâmite perante outros juízos. Agravo regimental desprovido.**

[...]

(Inq 4.327 AgR-segundo, Plenário, ministro Edson Fachin, *DJe* de 9 de agosto de 2018)

No mesmo sentido: Inq 4.483 AgR-segundo, Plenário, ministro Edson Fachin, julgamento em 19 de dezembro de 2017; Rcl 24.506, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, julgamento em 26 de junho de 2018; Inq 2.903 AgR, Plenário, ministro Teori Zavascki, *DJe* de 1º de julho de 2014; Inq 3.515 AgR, Plenário, ministro Marco Aurélio, julgamento em 13 de fevereiro de 2014, *DJe* de 14 de março de 2014.

Ademais, **o oferecimento das denúncias no Inq 4.921, a celebração de acordos de não persecução penal em inúmeras ações, a realização da instrução da presente ação penal e a circunstância de este processo já ter sido até mesmo incluído em pauta para julgamento pelo Plenário, evidenciam, seguramente, a ausência de qualquer prejuízo que pudesse advir do cumprimento da regra geral de cisão dos feitos, mesmo que conexos fossem, com a permanência nesta Corte apenas das investigações em face dos detentores da prerrogativa de foro.**

Ainda que se verificasse a sustentada conexão com os inquéritos de n. 4.917, 4.918 e 4.919, forçoso seria reconhecer a **necessidade de**

AP 2011 / DF

submeter à livre distribuição o primeiro inquérito relativo aos eventos do dia 8 de janeiro de 2023, cujos investigados possuem prerrogativa de foro, em observância à garantia do juiz natural.

De igual forma, não vislumbro conexão entre os fatos apurados nos inquéritos de n. 4.921 e 4.922 e aqueles em investigação no Inq 4.781, das “Fake News”. Ao contrário, a ausência de conexão, nesse caso, parece-me ainda mais evidente, com todas as vênias devidas.

Da leitura da Portaria n. 69/2019/GP extrai-se que o Inq 4.781 tem por objeto:

[...] a investigação de notícias fraudulentas (*fake news*), falsas comunicações de crimes, denúncias caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de *animus caluniandi*, *diffamandi* ou *injuriandi*, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros; bem como de seus familiares, quando houver relação com a dignidade dos Ministros, inclusive o vazamento de informações e documentos sigilosos, com o intuito de atribuir e/ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte, por parte daqueles que têm o dever legal de preservar o sigilo; e a verificação da existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário e ao Estado de Direito.

Depois de consignada a constitucionalidade do mencionado ato administrativo, a Procuradoria-Geral da República requereu a instauração do Inq 4.828, com a finalidade de apurar “fatos ocorridos no dia 19 de abril de 2020 e seus antecedentes”, relacionados a “aglomerações de indivíduos diante de quartéis do Exército brasileiro das quais foram noticiadas pretensões de animosidade entre as Forças Armadas e as instituições nacionais”.

AP 2011 / DF

Referido procedimento investigativo acabou arquivado. Porém, na sequência, houve a instauração do Inq 4.874, distribuído por prevenção conforme decidiu, de ofício, o ministro Alexandre de Moraes, Relator do primeiro.

Esse inquérito surgiu para investigar os “eventos nºs 01, 02, 03, 04 e 05”, apontados em relatório da Polícia Federal, os quais podem ser assim sintetizados: (i) recebimentos de valores no exterior relativos à monetização do canal “Terça-Livre”, do jornalista Allan dos Santos; (ii) articulação dos integrantes de tal grupo a fim de criar obstáculos a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI das *Fake News*), inclusive com a tentativa de convencer a deputada federal Bia Kicis a “derrubar” a convocação da CPI; (iii) doação de valores ao canal “Terça-Livre” por meio de plataformas *crowdfunding* ou diretamente, com destaque para transações supostamente realizadas por servidores públicos; (iv) análise bancária preliminar da empresa Inclutech H Tecnologia da Informação Ltda., de propriedade de Sérgio Lima, que teria identificado repasses oriundos de contas associadas a Luís Felipe Belmonte, de parlamentares, e de uma confecção situada em São Paulo cuja proprietária seria “uma pessoa de origem estrangeira (chinesa)”; e (v) renegociação de valor atinente a aluguel à empresa Petrobras de imóvel pertencente a Otávio Fakhoury.

Analisando os fatos objeto de apuração inicial no Inq 4.781 e no Inq 4.874, tampouco identifico, à luz do citado no art. 76 do Código de Processo Penal, qualquer conexão probatória com as condutas denunciadas no Inq 4.921 e ora em julgamento na presente ação.

Finalmente, a **mera referência** à atuação de autoridades com foro por prerrogativa de função (no caso, parlamentares federais) não é suficiente para atrair a competência desta Corte na supervisão judicial da fase administrativa e no processamento da ação penal.

AP 2011 / DF

Importa enfatizar, na linha do quanto já exposto, que do exame dos autos, **no que se refere à presente ação penal, oriunda do Inq 4.921, não se extrai indício de ato ilícito que, atribuído às autoridades com prerrogativa de foro perante este Tribunal, pudesse lhes render a condição de investigadas e, dessa forma, ensejar, nos termos do art. 102, I, “c” e “l”, da Lei Maior, a competência do Supremo.**

Esse entendimento, a afastar a ocorrência de usurpação da competência jurisdicional, é o que vem sendo adotado pelo Tribunal (HC 82.647, ministro Carlos Velloso; HC 153.417 ED-**segundos**, ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 2.101 AgR, ministra Ellen Gracie).

Bem a propósito, destaco trecho do voto condutor do **acórdão – unânime** – prolatado pela Segunda Turma no julgamento da Rcl 30.177 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia:

Este Supremo Tribunal assentou que “**não há de se cogitar de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal quando a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos travados por alvos de interceptação telefônica judicialmente autorizada, assim como a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior. Para que haja a atração da causa para o foro competente é imprescindível a constatação da existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais**” (Rcl n. 25.497-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2017).

Por fim, compulsando os autos dos inquéritos de n. 4.917, 4.918 e 4.919, instaurados contra os deputados federais Clarissa Tércio, Sílvia Waiãpi e André Fernandes, os quais supostamente teriam fomentado, por meio de publicações em suas redes sociais, a prática dos atos a que

AP 2011 / DF

assistimos em 8 de janeiro de 2023, é possível constatar que, desde 19 de maio de 2023, o Ministério Público Federal, titular da ação penal a eventualmente ser formalizada, manifestou-se postulando o arquivamento das investigações. Segundo o *Parquet*, até aquele momento estavam afastados os indícios de que os parlamentares federais em questão tivessem concorrido, “ainda que por incitação, para os crimes executados no dia 8 de janeiro de 2023, inexistindo justa causa para o prosseguimento das investigações ou para a instauração de ação penal”.

Então, com as mais respeitosas vênias, e atento à pacífica orientação jurisprudencial desta Corte, não vejo como recusar a promoção de arquivamento feita pelo Ministério Público, notadamente quando fundamentada na ausência de elementos que permitam ao Procurador-Geral da República formar a *opinio delicti* (Pet 2.509 AgR, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJ de 25 de junho de 2004). Aliás, vale recordar que, em 16 de abril de 2019, houve promoção de arquivamento – pela então Procuradora-Geral da República, Dra. Raquel Dodge – nos autos do Inq 4.781, cuja tramitação, de acordo com o Relator, também justificaria o processamento nesta Corte do Inq 4.921, do Inq 4.922 e das ações penais deles decorrentes.

A promoção do arquivamento dos inquéritos de n. 4.917, 4.918 e 4.919, além de explicitar a disposição do Ministério Público de não mais postular a realização de diligências probatórias para investigação dos parlamentares federais Clarissa Tércio, Sílvia Waiãpi e André Fernandes, faz desaparecer por completo o sustentado vínculo probatório a justificar a competência do Supremo para processar e julgar o presente feito.

Assim, entendo, preliminarmente, renovando meu pedido de respeitosas vênias a quem pensa de outra forma, que é caso de reconhecer a incompetência deste Tribunal para o julgamento da presente ação penal,

AP 2011 / DF

oriunda do Inq 4.921, e de remeter os autos à Justiça Federal do Distrito Federal, **inclusive para convalidação dos atos de conteúdo decisório**, ante a natureza dos crimes tipificados na denúncia.

Dada a incompetência absoluta do Supremo para processar e julgar o feito, reputo também ocorrido desrespeito ao princípio do promotor natural, uma vez que a parte ré deveria ter sido denunciada por membro do Ministério Público que oficia perante a Justiça Federal do Distrito Federal.

2. Da ausência de individualização da conduta da parte ré

Embora a denúncia tenha sido recebida pela maioria do Plenário, o vício consistente na inépcia da inicial não se convalida, na medida em que subsiste, integralmente, a lesão ao contraditório e ao exercício do direito à ampla defesa.

A peça acusatória deveria apontar, à luz da prova produzida na fase pré-processual, os elementos essenciais das figuras típicas dos delitos previstos no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais) e no art. 288, *caput* (associação criminosa), além de estabelecer a indispensável vinculação da conduta individual da parte acusada com os eventos delituosos que lhe foram imputados em abstrato.

Essa foi a ótica adotada pela Segunda Turma ao julgar o HC 89.427, Relator o ministro Celso de Mello, de cujo acórdão destaco o fragmento a seguir:

A denúncia – enquanto instrumento formalmente consubstanciador da acusação penal – constitui peça processual de indiscutível relevo jurídico. Ela, antes de mais nada, ao delimitar o âmbito temático da imputação penal, define a própria *res in judicio deducta*. **A peça acusatória, por isso**

AP 2011 / DF

mesmo, deve conter a exposição do fato delituoso, em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias. Essa narração, ainda que sucinta, impõe-se ao acusador como exigência derivada do postulado constitucional que assegura, ao réu, o exercício, em plenitude, do direito de defesa. **Denúncia que não descreve, adequadamente, o fato criminoso e que também deixa de estabelecer a necessária vinculação da conduta individual de cada agente ao evento delituoso qualifica-se como denúncia inepta.**

(Grifei)

Pedindo as mais respeitosas vênias ao Ministro Relator, e em que pese a fundamentação adotada por Sua Excelência, considero a inicial inepta. A acusação não identificou nem expôs adequadamente as condutas supostamente ilícitas, com todas as suas circunstâncias, falhando em demonstrar qual e como teria sido a participação da parte ré.

Com efeito, a denúncia, embora extensa e complementada por posterior cota ministerial, limita-se a discorrer sobre a gravidade abstrata dos delitos investigados e a apresentar imagens do acampamento e das atividades lá realizadas na tentativa de evidenciar certa organização e estabilidade nas supostas condutas criminosas. **Contudo, respeitosamente, não há nela qualquer elemento que estabeleça uma conexão mínima entre os fatos narrados e eventuais condutas – comissivas ou omissivas – da pessoa denunciada.**

A única alegação específica contra a parte é de que ela permaneceu acampada “até o dia 9 de janeiro de 2023, em frente ao Quartel General do Exército, localizado no Setor Militar Urbano, em Brasília/DF, incitando, publicamente, animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais”.

Segundo a acusação, a parte denunciada, “plenamente ciente dos objetivos delituosos de quem ali se encontrava” e “com absoluta

AP 2011 / DF

consciência e vontade, até porque as manifestações, faixas, gritos de ordem, marchas e outras formas de expressão eram públicas e ostensivas, aderiu ao grupo de acampados e aos seus dolosos fins ilícitos, passando a integrar a associação criminosa que estavelmente se instalou em frente ao Quartel General do Exército”.

O órgão acusador não descreve, porém, como se teria dado a participação da parte ré nos eventos criminosos, restringindo-se a afirmar que ela, **estando presente no ambiente do acampamento – sem especificar sequer o tempo de permanência no local –**, teria consentido com os atos supostamente criminosos imputados.

Em resumo, a denúncia não atendeu as exigências mínimas para a formulação de uma acusação válida, conforme os critérios estabelecidos na obra de referência de João Mendes de Almeida Júnior (*O processo criminal brasileiro*. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959. v. II, p. 183):

[...] uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (*quis*), os meios que empregou (*quibus auxiliis*), o malefício que produziu (*quid*), os motivos que o determinaram (*quomodo*), o lugar onde a praticou (*ubi*), o tempo (quando).

Ademais, em se tratando de **crime cometido em coautoria**, o art. 5º, LV, da Constituição Federal e o art. 41 do Código de Processo Penal exigem, para o ajuizamento de ação penal, a individualização das condutas criminosas atribuídas. Isso é necessário para que se possa compreender as imputações e para que os acusados exerçam o direito ao contraditório e à ampla defesa, dentro do devido processo legal.

Ora, a parte tem o direito de se defender dos fatos que lhe são atribuídos, os quais devem ser suficientemente descritos, isto é, delineados no tempo e no espaço. Não se mostra viável uma acusação em

AP 2011 / DF

que se sustente a responsabilidade penal com base apenas na presença da pessoa em acampamento no Quartel-General do Exército, presumindo-se, de forma objetiva, a prática dos delitos imputados tão somente a partir da prisão realizada em 9 de janeiro de 2023. Tudo isso, ressalte-se, **sem que se saiba ao menos o tempo de permanência de cada indivíduo no local.**

Em suma, na ausência de descrição das condutas supostamente praticadas pela parte acusada, como ocorre neste caso, inviabiliza-se o contraditório e o exercício do direito à ampla defesa. Portanto, a denúncia deve ser considerada inepta, em consonância com os arts. 41 e 395, I, do Código de Processo Penal e a orientação desta Corte (Pet 5.631, ministra Rosa Weber).

3. Dos crimes tipificados nos arts. 286, parágrafo único (incitação de animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constitucionais), e 288, caput, do Código Penal (associação criminosa): absolvição

No campo da jurisdição penal, a condenação exige a formação de um juízo de certeza, calcado em prova coesa, harmônica e inequívoca para que se conclua pela existência do crime – materialidade – e pela autoria delitiva.

A verificação dessa certeza está necessariamente sujeita às regras de produção e ônus da prova, as quais devem ser interpretadas e aplicadas em consonância com o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

Nesse contexto, Luigi Ferrajoli (*Direito e razão: Teoria do garantismo penal*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 56), em sua tese “cognitivismo ou decisionismo”, leciona:

Diferentemente de outros tipos de investigação, a composição jurisdicional, sem dúvida, é obrigatória e deve ser concluída em algum momento: assim, pois, se o dilema não é

AP 2011 / DF

resolúvel, prevalece a hipótese mais favorável ao acusado, graças a uma regra jurídica sobre as condições de aceitabilidade da verdade processual; ademais, cada uma das hipóteses fáticas formuladas no processo pode ser desmentida por uma prova ulterior incompatível com aquelas, só até que, conforme outra regra jurídica, não intervenha a presunção legal de verdade da “coisa julgada”.

(Grifei)

Corroborando essa perspectiva, o jurista Nicola Framarino dei Malatesta (*A lógica das provas em matéria criminal*. Tradução de Paolo Capitanio. Campinas: Bookseller, 2001. p. 88) enfatiza:

É importante ainda observar que o fim supremo do processo judiciário penal é a verificação do delito, em sua individualidade subjetiva e objetiva. Todo o processo penal, no que respeita ao conjunto das provas, só tem importância do ponto de vista da certeza do delito, alcançada ou não. Qualquer juízo não pode resolver senão em uma condenação ou absolvição e é precisamente a certeza conquistada de delito que legitima a condenação, como é a dúvida, ou, de outra forma, a não conquistada certeza do delito, que obriga à absolvição. O objeto principal da crítica criminal é, portanto, indagar como, da prova, pode legitimamente nascer a certeza do delito; o objetivo principal de suas investigações é, em outros termos, o estudo das provas de certeza.

(Grifei)

Mesmo em casos de crimes multitudinários, Márcio Augusto Friggi de Carvalho (*Crimes multitudinários. Revista Jurídica da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo*, São Paulo, v. 16, n. 2, p. 162-189, 2019. Disponível em: https://es.mpsp.mp.br/revista_esmp/index.php/RJESMP/SP/article/view/412. Acesso em: 27 abr. 2023) ressalta que **“ao acusador remanesce o ônus da prova da conduta a lesar ou a expor a risco de lesão o bem jurídico protegido”**.

AP 2011 / DF

Ainda que examinada a imputação sob essa perspectiva, dos delitos multitudinários, conforme destacou o Ministro Relator à luz do magistério de Friggi de Carvalho (ob. cit.), há que atentar para a ressalva feita por esse autor, para quem não se pode pretender responsabilizar aqueles que, de alguma forma, **em reunião inicialmente lícita, se opuseram diretamente aos crimes praticados por parte dos componentes ou que deles se distanciaram.**

A responsabilização penal coletiva, sem qualquer distinção a beneficiar aqueles que não concorreram, de forma dolosa, direta ou indiretamente, para a prática dos crimes a si imputados, além de vedada em nosso sistema, revela nítida despersonalização. Tal abordagem transforma o indivíduo em mero objeto do processo penal, como se fosse integrante de uma entidade abstrata dotada, unitariamente, de responsabilidade criminal.

No entanto, a óptica há muito sedimentada no Supremo Tribunal Federal **afasta, peremptoriamente, a aplicação da responsabilidade penal objetiva**, em observância ao dogma da responsabilidade com culpa (*nullum crimen sine culpa*).

A responsabilização criminal no concurso de pessoas exige, necessariamente, a prova dos seguintes elementos:

(i) Pluralidade de condutas, isto é, a soma de comportamentos individualizados que realizem ou concorram para a realização da figura descrita no tipo penal. Como ensina René Ariel Dotti (*Curso de direito penal: parte geral*. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 551), “há necessidade, portanto, de duas ou mais condutas dirigidas ao mesmo objetivo, *i.e.*, à realização do verbo indicado pelo núcleo do tipo legal de crime”.

AP 2011 / DF

(ii) Relação de causalidade física, que consiste no nexo de causalidade da conduta concorrente preordenada a alcançar o resultado pretendido pelos autores, coautores e partícipes do fato. Assim, “para ser punível a atividade deve ser causa próxima ou remota do evento” (ob. cit.), sendo esse o “aspecto objetivo do concurso de agentes e que permite estabelecer o começo da responsabilidade penal do parceiro” (ob. cit.).

(iii) Homogeneidade do elemento subjetivo do tipo, caracterizada pela consciência e vontade de concorrer, de qualquer modo, para a ação ilícita de outrem visando realizar o fato punível (ob. cit.).

Firmadas essas premissas, examino, inicialmente, a prova das elementares do crime de incitação de animosidade entre as Forças Armadas e os Poderes constitucionais (CP, art. 286, parágrafo único).

O tipo do art. 286, *caput* e parágrafo único, do Código Penal está assim descrito:

Art. 286. Incitar, publicamente, a prática de crime:

Pena – detenção, de 3 (três) a 6 (seis) meses, ou multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem incita, publicamente, animosidade entre as Forças Armadas, ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade.

Incitar consiste em **estimular ou instigar a prática de crime**. A propósito do tipo penal em referência, Guilherme de Souza Nucci (*Código Penal comentado*. 22. ed. Rio de Janeiro: Forense p. 1212) expõe que

[...] **aquele que estimula ou instiga animosidade** (hostilidade ou aversão) entre as Forças Armadas (Exército contra Marinha, Exército contra Aeronáutica, Marinha contra Aeronáutica) ou entre qualquer dessas Forças em relação aos poderes da República (Executivo, Legislativo ou Judiciário)

AP 2011 / DF

permite a configuração do crime.
(Grifei)

A pretensão acusatória submetida a julgamento nesta ação penal é dirigida contra pessoa que foi presa no acampamento instalado em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília no dia seguinte aos eventos ocorridos na Praça dos Três Poderes.

Logo na manhã de 9 de janeiro de 2023, a Polícia Militar foi ao local e solicitou que a parte ré e as demais pessoas acampadas recolhessem seus pertences e embarcassem em um ônibus, sem que houvesse ciência da prisão iminente. Os detidos, agindo de boa-fé, obedeceram às determinações da polícia.

Nesse sentido, destaco as declarações prestadas na fase pré-processual por Carlos Eduardo Melo de Souza, Comandante do Bope da Polícia Militar no Distrito Federal, que participou da operação:

[...] Que reuniu os Policiais Militares sob seu comando às seis horas da manhã na área próxima à Igreja Rainha da Paz, dando início efetivo ao trabalho de recolhimento das pessoas acampadas por volta das 7h30; Que as pessoas foram então informadas para se deslocar para os ônibus através de megafones; **Que tudo transcorreu com tranquilidade; Que foi dado o prazo de uma hora para que os presentes organizassem seus pertences e subissem nos ônibus [...]** Que todos os presentes obedeceram de forma serena e adentraram nos veículos carregando seus bens; **Que não foi necessário o uso de uso de força, nem houve tentativa de fuga;** Que os ônibus foram escoltados até a Superintendência de Polícia Federal do Distrito Federal e, em seguida, até a Academia Nacional de Polícia da Polícia Federal, localizada em Sobradinho/DF, para a realização das medidas cabíveis.

Os depoimentos dos demais agentes que atuaram nas diligências

AP 2011 / DF

convergem com as declarações do oficial.

Na fase inquisitorial, o interrogatório da parte ré não acrescentou nada relevante à elucidação dos fatos ou à identificação de condutas delituosas. As declarações prestadas por ela e pelos demais investigados no Inq 4.921 foram reduzidas a termo em formulários padronizados, preenchidos manualmente, com perguntas previamente estabelecidas e sem espaço adequado para o registro detalhado das versões individuais dos detidos. As perguntas se limitavam a dados de qualificação, renda, financiamento da viagem a Brasília, data de chegada, redes sociais utilizadas, participação nas manifestações ocorridas na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023, danos a bens e capacidade de apontar alguém responsável por eventuais danos ao patrimônio público.

A fragilidade das provas produzidas na fase administrativa era evidente, tanto que, no momento do oferecimento da denúncia, a própria acusação reconheceu a necessidade de diligências complementares para identificar a parte denunciada como autora dos fatos. Dessa forma, não havia suporte probatório suficiente sequer para o recebimento da denúncia, dada a ausência de indícios fundados de autoria.

Vale salientar, com a licença dos que pensam de forma diferente, que a confissão de réus em acordos de não persecução penal (ANPP) não ostenta aptidão probatória para embasar uma condenação.

De acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, a condenação não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos de informação obtidos na fase pré-processual, como, no caso, as “confissões circunstanciadas” realizadas para a formalização de ANPP. Portanto, eventual condenação embasada na confissão de réu que celebrou o acordo seria uma violação direta ao dispositivo processual mencionado, assim como ao princípio encerrado no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

AP 2011 / DF

A assunção extrajudicial de culpa no ANPP se assemelha à confissão da prática de infração penal perante autoridade policial ou ministerial. Somente tem valor probatório – como dado extrajudicial – e pode ser utilizada para subsidiar a denúncia no caso de descumprimento do acordo, “levando o Ministério Público a oferecer denúncia” (CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. *Manual do acordo de não persecução penal à luz da Lei 13.963/2019 (Pacote Anticrime)*. Salvador: JusPodivm, 2020. p. 113).

Ademais, as declarações prestadas pela pessoa investigada ou denunciada que firma o acordo não podem ser equiparadas a provas de natureza testemunhal. Testemunha, conforme a doutrina, “é o indivíduo que, não sendo parte nem sujeito interessado no processo, depõe perante um juiz sobre fatos pretéritos relevantes para o processo e que tenham sido percebidos pelos seus sentidos” (BADARÓ, Gustavo Henrique. *Processo penal*. 6. ed. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018. p. 483).

O investigado ou corréu que celebra ANPP não pode ser considerado testemunha, já que não está obrigado a dizer a verdade. Aliás, esta Corte já assentou há muito tempo, ao julgar a AP 470, que “o sistema processual brasileiro não admite a oitiva de corréu na qualidade de testemunha ou, mesmo, de informante” (AP 470 AgR-sétimo, Tribunal Pleno, ministro Joaquim Barbosa, *DJe* de 2 de outubro de 2009).

A confissão realizada pela parte que celebra acordo de não persecução penal não ostenta sequer o valor probatório reconhecido ao depoimento do colaborador premiado, uma vez que, nos termos do art. 4º, § 14, da Lei n. 12.850/2013, esse último ainda se encontra submetido ao compromisso de dizer a verdade. Mesmo assim, as declarações do colaborador têm valor probatório limitado, pois a legislação não permite a condenação exclusivamente baseada em seu depoimento (Lei n. 12.850/2013, art. 16, § 4º). Dessa forma, não se reconhece valor probatório suficiente para um decreto condenatório quando os depoimentos dos colaboradores não forem corroborados por elementos externos e

AP 2011 / DF

independentes de confirmação.

Em síntese, as provas produzidas extrajudicialmente se mostram insuficientes para fundamentar uma decisão condenatória contra a parte denunciada.

O quadro probatório não melhora na fase judicial. As declarações dos policiais militares não comprovaram nenhuma participação nos crimes imputados à parte ré, já que descreveram apenas o momento da condução dos acampados até a Superintendência da Polícia Federal, onde se consumou a prisão. Os relatos, por certo, não indicaram qualquer conduta, individual ou coletiva, que caracterizasse a prática dos crimes narrados na denúncia, pois a atuação dos agentes de polícia se restringiu ao apoio operacional para conduzir as pessoas, as quais nem sequer tinham conhecimento de que seriam presas.

As declarações da parte ré também não fornecem suporte para um decreto condenatório, porque tampouco sinalizam qualquer ação ou manifestação concreta que pudesse configurar a prática de instigação ou estímulo à animosidade entre as Forças Armadas e os Poderes constitucionais.

Vale destacar que as manifestações realizadas pelos acampados eram bastante diversas e heterogêneas, abrangendo desde pautas ligadas aos costumes até reivindicações políticas variadas. Não se pode afirmar – até porque não há prova nesse sentido – que todos os integrantes do acampamento tinham, indistintamente, o propósito comum de incitar as Forças Armadas à deposição do governo constituído ou à abolição violenta do Estado democrático de direito. Tampouco há elementos materiais de prova que apontem a atuação concreta da parte ré no sentido de instigar ou estimular a prática de quaisquer crimes.

De forma semelhante, os autos não contêm provas suficientes para

AP 2011 / DF

sustentar o recebimento da denúncia, como já argumentei em outros votos, nem para embasar eventual condenação pelo crime do art. 288, *caput*, do Código Penal.

A conduta típica do *caput* do art. 288 consiste na associação (união, agrupamento, reunião) – de três ou mais pessoas com o fim específico de **cometer crimes indeterminados**.

A associação criminosa, além de precisa delimitação de tarefas entre seus membros, deve se apresentar **estabilidade, permanência e certa durabilidade, traço que diferencia tal delito do concurso eventual de pessoas**.

Rememore-se, quanto ao ponto, o que diz a doutrina:

Voltando à nova definição do crime de associação criminosa, deve-se reiterar que ela tem como objetivo específico a prática de crimes indeterminados. No entanto, **se a associação objetivar a prática de um ou outro crime, determinados, ainda que sejam três ou mais pessoas participantes, e que objetive praticar mais de um crime, determinados, não se tipificará a associação criminosa**, na medida em que sua elementar típica exige finalidade indeterminada de crimes, mas configurará somente o conhecido – e, por vezes, “esquecido” – concurso eventual de pessoas.

[...]

É absolutamente indispensável narrar descritivamente em que consiste a associação criminosa, demonstrar e descrever analiticamente a existência das elementares normativas e subjetivas de dita associação, sob pena de pecar por falta de demonstração da existência de elementares constitutivas desse crime. Na verdade, a estrutura central do núcleo do crime de associação criminosa reside na consciência e vontade de os agentes organizarem-se em associação criminosa, com o fim específico de praticar crimes indeterminados, que é o

AP 2011 / DF

seu imprescindível elemento subjetivo especial do injusto.

Associação criminosa é crime de perigo comum e abstrato, de concurso necessário e de caráter permanente, inconfundível, portanto, com o concurso eventual de pessoas, a conhecida coautoria. **É indispensável que os componentes da associação criminosa concertem previamente a específica prática de crimes indeterminados, como objetivo e fim do grupo, mas esses aspectos além de narrados devem ser, concretamente, demonstrados que estão presentes em uma suposta ação delituosa.**

(Associação criminosa e responsabilidade pelos crimes por ela praticados. Disponível em: <https://www.cezarbitencourt.adv.br/index.php/artigos/46-associacao-criminosa-e-responsabilidade-pelos-crimes-por-ela-praticados>. Acesso em: 27 abr. 2023 – Grifei)

A acusação não conseguiu reunir, **na instrução do presente feito**, elementos de prova suficientes de que **a parte ré tivesse se associado, de forma organizada e estável, com o fim específico de cometer uma série de crimes indeterminados**. Essas são elementares indispensáveis para a condenação pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal.

Ora, a condenação por associação criminosa exige a identificação dos membros do grupo e a demonstração de que tenham se associado previamente no intuito de cometer crimes. Sendo assim, não se pode presumir, *data venia*, que todos os acusados presos no acampamento instalado em frente ao Quartel-General do Exército no dia seguinte aos eventos do 8 de Janeiro mantivessem, indistintamente, tal vínculo associativo, com certa estabilidade e o objetivo de praticar delitos indeterminados.

Era dever da acusação esmiuçar as condutas de cada réu, o que, na verdade, não fez, apresentando uma denúncia genérica quanto às circunstâncias dos crimes em análise (quem, o quê, onde, quando, por quê e com quem).

AP 2011 / DF

É possível que tenha havido associação criminosa entre algumas das pessoas que participaram da invasão e depredação de prédios públicos. No entanto, os membros dessa associação deveriam ter sido apontados pela acusação, com a indicação concreta dos vínculos entre eles e as funções desempenhadas por cada um. Não é razoável imputar esse crime indistintamente a todos os acusados presos. Há que demonstrar a extensão da associação criminosa, identificando-se os seus membros e as elementares acima referidas, sob pena de transformar em associação criminosa o que era mero concurso eventual de pessoas.

Vem a talho, por fim, a advertência feita por Denise Hammerschmidt, Emily Garcia e Fernando Antunes Soubhia (*O grito pela democracia: crimes contra o estado democrático de direito brasileiro*. Curitiba: Juruá, 2022. p. 72), no que concerne à aplicação de tipos penais abertos, como o de incitação de animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constitucionais, que está sujeita a elevada carga de valoração e a interpretações variáveis ao longo do tempo. Vejamos:

O resultado do surgimento dessa estrutura punitivo-populista é que criminalidade e o controle do crime tornaram-se centrais à governança no final do século XX. **As políticas de Justiça Criminal tornaram-se eminentemente simbólicas, servindo de catarse após tragédias exploradas extensa e maniqueisticamente pela mídia e, para essa retórica política recém-desenvolvida, as vítimas de crimes e a sociedade lutam lado a lado contra um enxame de infratores provenientes de “subclasses”.** Neste discurso, os dois lados bem definidos são os elementos de um jogo de soma zero e ser a favor de medidas que protejam o infrator dos excessos estatais equivale a ser contra as vítimas e contra a sociedade como um todo.

Assim, considerando a velocidade que os ventos mudam e a facilidade com a qual as massas são manipuladas na era dos grupos de *WhatsApp*, há que se tomar muita cautela com tipos penais abertos como o presente, que dependem de

AP 2011 / DF

conhecimentos e interpretações variáveis ao longo do tempo, sob pena de se permitir a utilização de tão relevante norma penal como mais um instrumento de opressão.

(Grifei)

Em suma, para além da variedade das pautas defendidas no exercício do direito de livre manifestação, inúmeras pessoas limitaram-se a pernoitar no acampamento entre 8 e 9 de janeiro de 2023. Muitas ali permaneceram somente no fim de semana de 7 a 9 de janeiro. Havia significativa rotatividade do público naquele ambiente aberto, sendo plausível cogitar que diversos manifestantes tenham chegado às vésperas dos eventos de 8 de janeiro, enquanto outros tenham partido de lá antes. Nem a inicial nem as provas produzidas nos autos apontam um grupo específico presente no local por período prolongado, o que torna difícil argumentar com a possibilidade da prática dos delitos de associação criminosa ou de incitação ao crime, na forma prevista no parágrafo único do art. 286 do Código Penal.

Desse modo, tendo em mente as elementares dos crimes em análise, **concluo** pela absolvição da parte ré, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em relação aos crimes que lhe foram imputados.

4. Conclusão

Do exposto, com o mais absoluto respeito ao voto apresentado pelo eminente Relator, peço vênica para divergir de Sua Excelência e de quem mais o acompanhe, para pronunciar-me no sentido de, caso superadas as preliminares de incompetência do Supremo e de inépcia da inicial, **absolver** o réu de todos os crimes que lhe foram imputados, fazendo-o com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

19/11/2024

PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 2.011 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
REVISOR	: MIN. NUNES MARQUES
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: VICENTE CAVALINI FILHO
ADV.(A/S)	: LUIZ FERNANDO VILASBOAS
ADV.(A/S)	: RHANA SARAIH MOTA DA SILVA

VOTO-VOGAL

O Senhor Ministro ANDRÉ MENDONÇA:

1. AGENOR PISETTA (AP 1220), BELCHIOR ALVES DOS REIS (AP 1251), GUILHERME CAZELLI CONDE (AP 1289), JULIO OLIMPIO BERNARDES (AP 1302), EDINEIA FATIMA DA SILVA SERGIO (AP 1346), NICEIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA (AP 1357), MERCIA CRUZ MESQUITA (AP 1478), HELMI TAVARES DE OLIVEIRA (AP 1528), CESAR SANTOS DE LIMA (AP 1562), DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (AP 1605), IVAN MANOEL RECH (AP 1820), VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA MOREIRA (AP 1827), SERGIO ALEXANDRE COELHO (AP 1936), MARCO AURELIO BARBOSA (AP 1967) E VICENTE CAVALINI FILHO (AP 2011), foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República como incursos nos delitos dos arts. 288 e 286, parágrafo único, ambos do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e local narradas nas iniciais acusatórias, teriam se associado com o objetivo de praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito e de incitar as Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 288, *caput*), bem como teriam efetivamente incitado, publicamente, a animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único).

2. Das exórdias se colhe a seguinte narrativa em comum:

AP 2011 / DF

“Na data de 30 de outubro de 2022, finalizado o pleito eleitoral ao cargo de Presidente da República, o Tribunal Superior Eleitoral proclamou o resultado e os eleitos, sagrando-se vencedor o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. A partir desse fato, verificou-se a convocação, por meio das mídias sociais, de milhares de pessoas para reunirem-se em acampamentos nas portas de unidades militares, tendo por mote principal uma intervenção militar, com a tomada dos Poderes Constituídos e a instalação de uma ditadura.

No dia 12 de dezembro de 2022, ocorreram manifestações violentas contra a realização da diplomação, seguindo-se, nesse mesmo dia, os primeiros atos de maior gravidade, com a queima de veículos, incêndios e tentativa de invasão e destruição da sede da Polícia Federal na capital da República.

Traçado esse panorama, a agregação de pessoas e o insuflamento à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ao golpe de Estado levou centenas de pessoas, no início do ano de 2023, após a posse do Presidente eleito, a aderirem ao acampamento em frente ao Quartel General do Exército, no Setor Militar Urbano, em Brasília/DF.

O acampamento passou a se constituir como ponto de encontro para uma associação estável e permanente, que ali se estabeleceu e permaneceu inclusive durante a prática dos atos de vandalismo e protestos antidemocráticos consumados no dia 8 de janeiro de 2023, com a invasão das sedes dos Três Poderes na Esplanada dos Ministérios.”

3. Em julgamento no Plenário Virtual, as denúncias foram integralmente recebidas, por maioria de votos. Fiquei vencido, *(i)* entendendo pela incompetência absoluta desta Corte e pela necessidade de remessa dos casos à primeira instância; *(ii)* e, ainda, superada a matéria preliminar, subsidiariamente, votei pela rejeição das denúncias, ante à ausência de indícios mínimos e suficientes da prática dos delitos narrados em petições iniciais acusatórias genéricas e que, a meu ver, não individualizaram minimamente as condutas.

AP 2011 / DF

4. Realizadas as citações, foram apresentadas as defesas prévias. Não efetivados, nos presentes casos, os acordos de não persecução penal (seja por recusa tácita, expressa, ou por não preenchimento de requisitos), prosseguiu-se em regular instrução, em todos os feitos ora pautados, após o que, ao final, vieram as alegações finais das partes, sendo os feitos disponibilizados para julgamento de mérito em ambiente virtual.

5. Feito este breve apanhado e acolhendo, no mais, os relatórios lançados pelo e. Ministro Alexandre de Moraes, passo ao voto propriamente.

Da preliminar de incompetência:

6. Inicialmente, reitero meu posicionamento quanto à ausência de competência deste Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento dos presentes casos. Assim, com a devida vênia aos entendimentos contrários, transcrevo o trecho pertinente de meus votos proferidos por ocasião do julgamento de recebimento das denúncias:

“(...) o julgamento originário perante o Supremo Tribunal Federal de pessoa não detentora de foro por prerrogativa de função é absolutamente excepcional e estritamente vinculado a hipóteses de conexão ou continência, nos termos da lei processual.

17. Essas hipóteses devem estar bem demonstradas e cercadas de mínima concretude, não apenas pautadas em possibilidades passíveis ou não de eventual materialização futura.

18. Tal entendimento visa, inclusive, a preservar a Corte e a racionalidade da prestação jurisdicional, bem como o caráter excepcional do julgamento por prerrogativa de foro, o qual, por um lado, é garantia apenas de determinados cargos e, por outro, acaba excluindo instâncias recursais a que os acusados em processos criminais normalmente teriam acesso.

19. A absoluta excepcionalidade com a qual deve ser

AP 2011 / DF

encarado o julgamento originário no Supremo Tribunal Federal em razão de foro por prerrogativa de função ganhou contornos ainda mais nítidos no passado recente, a partir do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, de Relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso.

20. Na ocasião, decidiu-se que o “foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas” (destaquei). Da decisão, de maio de 2018, se extrai o escopo de se reduzir a amplitude do popular “foro privilegiado”, interpretando-se o art. 102, I, da Constituição da República de maneira mais restritiva, de modo a que efetivamente configure apenas uma prerrogativa da função.

21. A alteração jurisprudencial ensejou a necessidade de se decidir quanto à forma de transição dos casos que já tramitavam no STF com base no entendimento superado. Na própria AP nº 937-QO/RJ se estabeleceu que ficaria prorrogada a competência da Corte para os casos nos quais já houvesse encerramento de instrução e despacho para intimação para apresentação de alegações finais.

22. Posteriormente essa regra de transição foi estendida também para casos nos quais, quando do julgamento da AP nº 937-QO/RJ, já houvesse denúncia oferecida e pendente de apreciação, a exemplo do que se verificou no Inq nº 4.641/DF, também de relatoria e. do Ministro Roberto Barroso —julgado em 29/05/2018—, e no Inq nº 4.343/GO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes —julgado em 26/06/2018.

23. Em ambos os casos as denúncias haviam sido oferecidas antes da mudança de entendimento trazida pela AP nº 937-QO/RJ, e estavam pendentes de apreciação.

24. Seguindo o espírito que moveu a decisão na AP nº 937-QO/RJ, tive a oportunidade de pontuar, no julgamento do AgR no Inq nº 4.513/PE, ser mesmo excepcional a prorrogação da competência do Pretório Excelso, devendo suas hipóteses ser interpretadas de forma estrita. Na ocasião do julgamento do AgR no Inq nº 4.513/PE essa premissa também foi assentada

AP 2011 / DF

pelo e. Ministro Roberto Barroso.

25. Disso se extrai, por exemplo, que um Senador da República que cometa um crime qualquer sem relação com seu mandato, não será julgado originariamente por esta Corte. Do mesmo modo, por hipótese, se um Deputado Federal cometer um crime durante o exercício do mandato, ainda que a conduta esteja relacionada ao mandato, não será julgado perante a Suprema Corte se não for reeleito e o caso ainda estiver em fase de investigação. Nesses dois casos, repiso, mesmo o crime tendo sido cometido por um Senador da República ou Deputado Federal durante o mandato, o julgamento não será perante o Supremo Tribunal Federal.

26. Verifica-se, assim, uma inegável tendência de se reduzir a competência originária criminal da Suprema Corte, até mesmo no sentido de melhor viabilizar os julgamentos realmente cabíveis neste Tribunal e, ainda, de se preservar a excepcionalidade da prerrogativa de foro.

27. Seguindo essa lógica, mesmo nas hipóteses de conexão e continência, quando há denunciados com foro e sem foro por prerrogativa de função, a regra tem sido o desmembramento do processo, mantendo-se no Supremo Tribunal Federal o julgamento apenas de quem possui o popular “foro privilegiado” e remetendo-se o processamento dos demais acusados para as instâncias ordinárias. Nesse sentido:

(...)

28. Das ementas colacionadas, que somente ilustram o teor de muitas outras, depreende-se, em síntese, (i) que a atração da competência originária desta Corte é absolutamente excepcional; (ii) que mesmo em caso de possível conexão, a regra tem sido o desmembramento e a remessa dos processos dos não detentores de foro por prerrogativa de função para a primeira instância; e, (iii) que a excepcionalíssima manutenção do processo nesta Corte deve ter a demonstração de prejuízo concreto e real na cisão do feito.

(...)

AP 2011 / DF

30. Assim, o que se tem é a atração da competência originária desta Corte, para que pessoas sem foro por prerrogativa de função sejam aqui julgadas originariamente, fora das hipóteses previstas na Constituição e da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. Com a devida vênia, há um evidente desrespeito ao princípio do juiz natural.

31. Ademais, as denúncias e os votos de recebimento do e. Relator não descrevem exatamente quais atos esses Deputados Federais teriam praticado. E mais, o fato concreto é que sequer houve o processamento conjunto das pessoas ora denunciadas com os parlamentares e as investigações destes já correm em separado.

32. É dizer: os detentores de foro por prerrogativa de função eventualmente denunciados não exercerão, de uma forma ou de outra, suas defesas no bojo dos processos instaurados pelas denúncias aqui em comento, pois, onde quer que tramitem tais processos, aqui ou na primeira instância, não figuram como partes neles. Não estarão, a princípio, nas audiências, não contraditarão testemunhas, não farão perguntas. Enfim, não são parte nesta relação processual.

(...)

46. Portanto, sem qualquer deliberação sobre o recebimento ou não das denúncias no Supremo Tribunal Federal, devem elas ser remetidas para Justiça Federal de primeira instância do Distrito Federal, medida que prestigia o princípio do Juiz Natural e se mostra, a meu ver, consentânea com a jurisprudência da Corte em outros casos.”

Da inépcia das iniciais:

7. Além da incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar as presentes ações penais, ressaltei também, por ocasião dos julgamentos de recebimento das exordiais, que elas eram ineptas, eis que não individualizaram suficientemente as condutas dos denunciados.

8. Reitero, aqui, essa compreensão, transcrevendo o trecho

AP 2011 / DF

pertinente, já lançado por ocasião do julgamento de recebimento das acusações, quando fiquei vencido:

“(…) as denúncias aqui tratadas, de teor praticamente idêntico, não individualizaram suficientemente as condutas.

59. Após tecerem considerações gerais sobre a reprovabilidade dos atos e sobre o contexto em que se deram, elas pontuam que o “acampamento passou a se constituir como ponto de encontro para uma associação estável e permanente, que ali se estabeleceu e permaneceu inclusive durante a prática dos atos de vandalismo e protestos antidemocráticos consumados no dia 8 de janeiro de 2023, com a invasão das sedes dos Três Poderes na Esplanada dos Ministérios”.

60. A seguir, as denúncias narram que a estabilidade e a permanência da associação criminosa seriam comprováveis pela perenidade do acampamento, o qual “já funcionava como uma espécie de vila, com local para refeições, feira, transporte, atendimento médico, sala para teatro de fantoches” e etc.

61. E, por fim, cada denúncia narra que a pessoa denunciada teria aderido à tal associação criminosa ao se dirigir para o acampamento, ciente dos objetivos delituosos de quem ali se encontrava, “até porque as manifestações, faixas, gritos de ordem e outras formas de expressão eram públicas e ostensivas”. Assim, cada denunciado, ao se unir ao acampamento, teria partilhado das manifestações e gritos de ordem, robustecendo a massa.

62. O problema desta narrativa da acusação, porém, é que ela pressupõe, sem comprovação, uma absoluta uniformidade e homogeneidade daquela massa de pessoas. Ademais, acaba por implicar responsabilização objetiva dos denunciados, pelo simples fato de estarem no acampamento, a qual é vedada pelo ordenamento jurídico e pela doutrina penal.

63. Não se olvida de que no acampamento, seguramente, havia pessoas mal-intencionadas, pessoas que desejavam um golpe de Estado, pessoas cujos motivos de presença no local se harmonizavam com o dolo narrado pelo

AP 2011 / DF

Ministério Público. E é possível, até mesmo, considerar que havia um bom número delas.

64. Tais circunstâncias, todavia, não autorizam a presunção de que rigorosamente todos que lá estavam agiam com as mesmas intenções e, portanto, não permitem a imputação uniforme contra todas aquelas pessoas, sem que se apontem elementos que demonstrem, individualmente, a culpabilidade subjetiva de cada qual.

65. Do que se tem notícia, nem todas as pessoas acampadas aprovaram os atos de vandalismo. As próprias denúncias admitem este fato, ao afirmarem não possuir provas de que os aqui denunciados, a despeito de acampados, estiveram na Praça dos Três Poderes e praticaram vandalismo em 8 de janeiro.

66. Generalizações são sempre temerárias. Em Direito Penal, e *in malam partem*, inadmissíveis.

67. Não comparando, de forma alguma, a natureza das aglomerações, mas buscando, apenas, ilustrar o quanto, em qualquer multidão com milhares de pessoas, há sempre grande diversidade de intenções, importa recordar as manifestações que tomaram as ruas do Brasil em junho de 2013. Parece incontroverso que, dentre aqueles manifestantes, havia quem protestava em razão de tarifas de ônibus coletivos; havia outros tantos que, democraticamente, protestavam contra um partido político em particular; outros pediam melhores serviços de saúde e educação; outros protestavam contra a corrupção; e, outros, contra tudo isso a uma só vez. Havia também curiosos e aqueles que praticaram vandalismo.

68. Os acampamentos existiram em vários lugares do Brasil e não foram coibidos pelos Poderes Públicos municipais, estaduais ou federais. Perduraram por meses, sem qualquer medida efetiva, de quaisquer dos Poderes, em quaisquer locais, para a desmobilização.

69. Se um denunciado, ao se juntar aos acampados, estava aderindo a uma associação criminosa já instalada e estável, que funcionava há semanas de forma pública e

AP 2011 / DF

ostensiva, e se tudo era tão claro como a narrativa das denúncias pretende, as ordens de desmobilização deveriam ter ocorrido antes. Todavia, a própria Procuradoria-Geral da República, aparentemente, não teria constatado a situação de flagrância de crimes anteriormente, mesmo com toda a ostensividade dos acampamentos.

70. É como se estar no acampamento até 8 de janeiro fosse permitido e, após, tivesse se tornado algo criminoso.

(...) é importante ressaltar que, quando da prisão dos aqui denunciados, no início da manhã do dia 9 de janeiro, a Polícia Militar solicitou que tais pessoas pegassem suas coisas e entrassem em ônibus. Ademais, consta que elas atenderam ao comando da polícia sem objeção e serenamente. Nesse sentido, registrem-se as palavras do Comandante do BOPE da Polícia Militar no Distrito Federal, que participou da operação:

‘Que reuniu os Policiais Militares sob seu comando às seis horas da manhã na área próxima à Igreja Rainha da Paz, **dando início efetivo ao trabalho de recolhimento das pessoas acampadas por volta das 7h30**; Que as pessoas foram então informadas para se deslocar para os ônibus através de megafones; **Que tudo transcorreu com tranquilidade**; Que foi dado o prazo de uma hora para que os presentes organizassem seus pertences e subissem nos ônibus (...) **Que todos os presentes obedeceram de forma serena** e adentraram nos veículos carregando seus bens; **Que não foi necessário o uso de uso de força, nem houve tentativa de fuga**; Que os ônibus foram escoltados até a Superintendência de Polícia Federal do Distrito Federal e, em seguida, até a Academia Nacional de Polícia da Polícia Federal, localizada em Sobradinho/DF, para a realização das medidas cabíveis’ (e-doc. 1.918, p. 45, Carlos Eduardo Melo de Souza — destaquei).

73. Os depoimentos dos demais policiais que participaram da diligência vão no mesmo sentido. Em nada a dinâmica se assemelha com aquela típica que se verifica em relação a criminosos após uma ordem de prisão expressa. E, no caso, havia muitas centenas de pessoas. Ninguém tentou fugir e

AP 2011 / DF

ninguém tumultuou a diligência, conforme palavras dos policiais militares que estiveram na operação e foram ouvidos no inquérito. Ao que tudo indica, as pessoas foram convidadas a se desmobilizar e simplesmente entraram nos ônibus para tanto.

74. Ainda, além de não constar das denúncias, também os depoimentos dos policiais não apontaram qualquer especificidade nas condutas individuais de uns ou outros denunciados.

75. Do mesmo modo, os interrogatórios a que os detidos foram submetidos também não elucidaram melhor as questões ou trouxeram individualização mínima e adequada às condutas. A grande maioria dos acampados aqui denunciados respondeu apenas a formulários de uma folha cada, preenchidos a caneta, com perguntas limitadas e sem espaço próprio para que cada um fornecesse com detalhes sua própria versão ou se alongasse em explicações, constando apenas, além da qualificação, perguntas sobre profissão e renda, quem financiou a vinda para Brasília, quando chegou, quais as redes sociais que utiliza, se participou das manifestações na Praça dos Três Poderes, se danificou algum bem e se saberia apontar alguém que danificou.”

Do mérito:

9. Superadas as questões relativas à incompetência desta Suprema Corte e à ausência de mínima individualização das condutas dos denunciados nas narrativas da acusação, cumpre adentrar à análise de mérito.

10. E, nesse aspecto, forçoso reconhecer a ausência de provas aptas a ensejar decreto condenatório em relação a cada um dos réus aqui julgados.

11. A responsabilidade subjetiva de cada qual haveria de estar

AP 2011 / DF

demonstrada, não bastando a conclusão genérica de que, por estarem juntos em um local, todos ali tinham os mesmos desejos e intenções.

12. Quanto ao delito de associação criminosa, **Luiz Regis Prado** afirma que a presença do elemento subjetivo do injusto é essencial para a configuração do delito. É preciso consciência e vontade de os indivíduos se associaram *com o fim específico de cometerem crimes*. Assim, segundo o autor, se *“a associação formou-se com outro fim que não este (exemplo: com o fim de constituir empresa lícita que ao final se converteu em associação ilícita), não restará configurado o crime”* (PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Erika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. *Curso de Direito Penal Brasileiro. Parte Geral e Especial*. São Paulo: RT, 2015, p. 1203).

13. Também no crime de incitação de animosidade entre as Forças Armadas e os Poderes Constitucionais exige-se elemento subjetivo, isto é, o dolo, composto por consciência e vontade.

14. E para a condenação por quaisquer deles exige-se a comprovação, acima de dúvida razoável, do dolo, isto é, do elemento subjetivo, **de cada um dos indivíduos**.

15. O fato de os acampamentos em frente aos quartéis do Exército terem funcionado por meses Brasil afora, com faixas de intervenção militar e a presença de indivíduos mais exaltados e radicais, não retira a heterogeneidade do grupo e a possibilidade de diversidade de intenções. Veja-se que as próprias denúncias narraram que o acampamento *“já funcionava como uma espécie de vila, com local para refeições, feira, transporte, atendimento médico, sala para teatro de fantoches”*. Nesse contexto, se afigura, a meu ver, generalizante e equivocada a conclusão de que todos os que lá estavam tinham as mesmas intenções; que estavam unidos e conscientes de pertencerem a uma associação criminosa com o fim de praticarem delitos contra a democracia, ou que todos possuíam o intuito de incitar animosidade entre as Forças Armadas e os poderes

AP 2011 / DF

constituídos.

16. Mesmo em relação aos presos do dia anterior, detidos durante as manifestações e atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes em 08/01/2023, havia significativa heterogeneidade. Nesse sentido, a testemunha **Ricardo Ziegler Paes Leme**, Tenente da PMDF, ouvida na AP 1505, afirmou em juízo **conseguiu perceber motivações diferentes entre as pessoas** que estavam ali na manifestação. Segundo a testemunha, alguns reconheciam que sabiam que poderia haver confronto, mas outros diziam que não sabiam. Algumas nitidamente falaram que não sabiam, que estavam na manifestação e *“correram, seguiram uma manada”* e foram para o interior do Palácio. **Uma senhora disse que tinha vindo rezar pelo país.**

17. Na mesma AP 1505, a testemunha **José Eduardo Natale de Paula Pereira**, Major do Exército Brasileiro, afirmou que no dia 08/01/2023 estava trabalhando no Palácio do Planalto, como coordenador de segurança de instalações, e que comandou uma tropa na tentativa de contenção dos manifestantes. Afirmou que **que viu manifestantes com extintores tentando apagar focos de incêndio**. Durante a retomada, houve manifestantes que resistiram e outros que rezavam e cantavam o hino nacional. Afirmou também **que alguns manifestantes queriam intervenção militar, que outros eram contra a intervenção militar e diziam que as Forças Armadas não seriam a solução, que outros queriam recontagem de votos, e que outros, ainda, não sabiam explicar o que queriam. Havia também manifestantes contrários às depredações**. Já a testemunha Wallace França de Mello, Policial Legislativo Federal que estava de plantão no Senado na tarde de 08/01/2023, afirmou na AP 1060, em relação aos manifestantes, que o *“grupo era bastante heterogêneo, tinha gente de tudo quanto é (falha no áudio), bem misturado, não tinha comando, uma liderança”*.

18. O que se questiona, em suma, é a automática inclusão, na

AP 2011 / DF

associação criminosa e no desejo de incitar animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constituídos, **de todas as pessoas que acabaram presas em 09/01/2023 por estarem no acampamento**. Essa solução não é possível, dada a já mencionada heterogeneidade do grupo e configura, no meu sentir, vedada responsabilização objetiva.

19. Mesmo considerando o caráter multitudinário dos delitos, a doutrina de Márcio Augusto Friggi de Carvalho assevera que *“ao acusador remanesce o ônus da prova da conduta a lesar ou a expor a risco de lesão o bem jurídico protegido”* (CARVALHO. Márcio Augusto Friggi de. *Crimes Multitudinários*. Disponível em https://es.mpsp.mp.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/412). Em outras palavras, mesmo considerando o aspecto da multitudinarietà, não é possível simplesmente atribuir **a todos** automática responsabilidade.

20. Como afirmado pela Defensoria Pública da União na AP 1257, os diversos interrogatórios realizados nas centenas de ações penais mostraram que *“entre os presos havia pessoas, por exemplo, que iam ao acampamento vender bugigangas, trabalhar como cozinheira, comer. Essas práticas estão longe de ser criminosas e não indicam qualquer adesão a crime”*.

21. A acusação não comprovou e, a bem da verdade, sequer indicou efetivamente como exatamente cada um dos presos no acampamento aderiu e participou da associação criminosa e do delito de incitação de animosidade entre Forças Armadas e poderes constituídos, isto é, quais atos cada um praticou, o que fez, o que disse, limitando-se a acusação a reproduzir imputações genéricas para o fim de se fazer chegar à conclusão, isto sim, de que o simples fato de a pessoa estar no acampamento indicaria sua consciente adesão aos delitos.

22. De novo me valendo das palavras da Defensoria Pública da

AP 2011 / DF

União na AP 1257, *“a denúncia foi apresentada como um formulário, citando apenas os mesmos eventos genéricos sem indicar as condutas realizadas subjetivamente por cada acusado, de modo a meramente trocar seus nomes. É evidente que se está a tratar, portanto, da tentativa de aplicação de uma responsabilidade penal objetiva, a qual é veementemente vedada pelo Direito Penal de um Estado Democrático de Direito.”*

23. Em relação a todos os réus ora julgados, observa-se que não há provas sólidas quanto ao dolo - enquanto vontade livre e consciente de praticar os delitos narrados na inicial -, a par da simples admissão de cada réu de que estava, de fato, no acampamento, sem intenções criminosas ou violentas.

24. O policial militar José Roberto Soares da Silva, que esteve no ato de desmobilização do acampamento e prisão dos acampados no dia 09/01/2023, foi ouvido como testemunha em várias das ações penais, afirmou que não teve contato com as pessoas acampadas, pois sua função era de motorista do Coronel Carlos de Melo, e que não presenciou a prática de atos ilícitos ao passar em frente ao acampamento.

25. O policial militar Sargento Ronaldo Reis da Rocha, lotado no Batalhão de Operações Especiais em 09/01/2023, ouvido como testemunha em diferentes ações penais movidas contra outras pessoas detidas no acampamento, e que atuou como negociador durante a desmobilização, disse que sabia que o acampamento era formado por pessoas que não estavam contentes com o resultado das eleições, mas só teve contato com uma senhora, cujo nome não se recordou, que aparentava ter cerca de 55 anos de idade. Não presenciou atos criminosos no acampamento e que as pessoas eram pacíficas, tampouco estavam uniformizadas.

26. O Coronel Carlos Melo, da PMDF, era lotado no Batalhão de Operações Especiais em 09/01/2023 e, ouvido como testemunha em algumas ações penais movidas contra os presos no acampamento,

AP 2011 / DF

afirmou que, da perspectiva da cerca em volta do acampamento, não presenciou atos ilícitos, tampouco houve a apreensão de qualquer arma. Relata que foi o condutor das pessoas à sede da polícia federal e, somente lá foi informado pelo Delegado Federal que as pessoas seriam presas. Não se recordou de quaisquer dos réus ora em julgamento.

27. O policial militar Hermison Rangel, lotado no BOPE/DF, também ouvido como testemunha em algumas ações envolvendo diferentes pessoas presas no acampamento, afirmou que sua participação foi apenas de apoio na desmobilização da ocorrência, até mesmo “*irrelevante para a ocorrência*”, nas palavras da testemunha. Não teve contato com as pessoas que foram conduzidas nos ônibus.

28. Em suma, como se vê, penso que há, no mínimo, dúvida razoável quanto à homogeneidade de métodos, intenções, atitudes, e, especialmente, quanto ao dolo de cada um dos réus, o que macula a tese de que todos, por estarem lá, pertenciam a uma mesma associação criminosa. Essa dúvida há de ser resolvida nos termos do milenar adágio latino “*in dubio pro reo*”, o qual, por mais grave que sejam os fatos, não pode ser invertido ou desconsiderado. Assim, o ônus da prova de que cada um daqueles manifestantes havia conscientemente aderido às intenções criminosas era da acusação, ônus esse do qual, nos presentes casos, penso não se desincumbiu de forma minimamente satisfatória.

29. O fato de os acusados estarem no acampamento em 09/01/2023, não lhes transfere a incumbência de provar as próprias inocências, permanecendo com a acusação o encargo de provar as culpas.

30. Conforme Heleno Cláudio Fragoso, “*nenhuma pena pode ser aplicada sem a mais completa certeza da falta*”, eis que a pena “*atinge a dignidade a honra e a estima da pessoa, ferindo-a gravemente no plano moral, além de representar a perda de bens ou interesses materiais*” (Jurisprudência Criminal, vol. II. 3ª ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1973, p. 405).

AP 2011 / DF

31. Para Gustavo Badaró, a prova além da dúvida razoável é aquela que traz uma elevadíssima probabilidade:

“Em uma escala crescente, podem-se trabalhar com ‘modelos de constatação’ ou ‘critérios de convencimento’, ou ainda ‘standards probatórios’ variados: (i) ‘simples ‘preponderância de provas’ (*proponderance evidence*), que significa a mera probabilidade de um fato ter ocorrido; (ii) ‘prova clara e convincente’ (*clear and convincing evidence*), que pode ser identificada como uma probabilidade elevada; (iii) e ‘prova além da dúvida razoável’ (*beyond a reasonable doubt*), como uma probabilidade elevadíssima, que muito se aproxima da certeza. (...) Diferentemente do processo civil, a definição dos standards probatórios no processo penal não tem por objetivo eliminar ou distribuir os riscos de erros em razão da insuficiência probatória, mas sim distribuir os erros de forma a favorecer sistematicamente a posição do acusado. Justamente por isso se considera preferível absolver um (ou dois, ou dez, ou mil...) culpado do que condenar um inocente!” (BADARÓ, Gustavo Henrique. 4ªed. São Paulo: RT, 2016, p. 436/437).

32. Assim, o nível de evidência probatória, ou *standard* probatório, exigido para a condenação difere daquele, menor, para o simples recebimento da denúncia. E, nos casos dos autos ora em julgamento, não foi atingido.

33. Nos dizeres do e. Ministro Celso de Mello, citando ensinamento clássico de Mittermayer, “*se a culpabilidade não está completa e legalmente provada, o acusado não é culpado*” (AP 307, Pleno, 13/12/2004).

34. Ante o exposto, superadas as preliminares de incompetência absoluta e de inépcia da inicial, absolvo os acusados AGENOR PISETTA (AP 1220), BELCHIOR ALVES DOS REIS (AP 1251), GUILHERME CAZELLI CONDE (AP 1289), JULIO OLIMPIO BERNARDES (AP 1302),

AP 2011 / DF

EDINEIA FATIMA DA SILVA SERGIO (AP 1346), NICEIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA (AP 1357), MERCIA CRUZ MESQUITA (AP 1478), HELMI TAVARES DE OLIVEIRA (AP 1528), CESAR SANTOS DE LIMA (AP 1562), DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (AP 1605), IVAN MANOEL RECH (AP 1820), VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA MOREIRA (AP 1827), SERGIO ALEXANDRE COELHO (AP 1936), MARCO AURELIO BARBOSA (AP 1967) E VICENTE CAVALINI FILHO (AP 2011) de todas as imputações formuladas nas ações penais ora em julgamento, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO PENAL 2.011

PROCED. : DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES

REVISOR : MIN. NUNES MARQUES

AUTOR(A/S) (ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROC.(A/S) (ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

RÉU(É) (S) : VICENTE CAVALINI FILHO

ADV.(A/S) : LUIZ FERNANDO VILASBOAS (73716/PR)

ADV.(A/S) : RHANA SARAIH MOTA DA SILVA (55902/GO)

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação penal para condenar o réu VICENTE CAVALINI FILHO, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, *caput*, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos, consistente em: (1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; (1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre "Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado", com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução; (1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena; (1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena; (1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado; (1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente; (2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais); (3) R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. Havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 5º, do Código Penal. Após o trânsito em julgado: (a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados; (b) expeça-se guia de execução definitiva. Custas pelo condenado (art. 804 do Código de Processo Penal). Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros André Mendonça e Nunes Marques. Plenário, Sessão Virtual de

8.11.2024 a 18.11.2024.

Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário